

eman ta zabal zazu



Universidad
del País Vasco

Euskal Herriko
Unibertsitatea

TRABAJO FIN
DE MÁSTER
PROPIO

LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN EL PROCESO DE SELECCIÓN LABORAL

Nombre del Máster en el que se presenta el trabajo: Máster Propio de Protección de
Datos, Ciberseguridad y de Derecho de las TICs

Autoría: **Aneña Delgado, M. Aneña**

Dirección: **José Francisco Esteban, G. G. G.**

Año académico y fecha de depósito. 2021/2022. 12 de septiembre de 2022

Resumen

Este trabajo trata de dar una explicación a la pregunta qué se hace con los datos de las personas candidatas a un puesto de trabajo. Es más, se explica detalladamente si se está ante una ejecución de contrato, un consentimiento o de si, únicamente, es necesario el interés legítimo del empresario. Por otro, lado se hace un desarrollo en el caso de los datos de categorías especiales. Del mismo modo, es importante tener presente la conservación de esos datos y durante cuánto tiempo se pueden conservar.

Lan honen helburua da lanpostu baterako hautagaien datuekin egiten den galderari azalpen bat ematea. Are gehiago, zehatz-mehatz azaltzen da kontratua edo adostasuna betearazi behar den edo enpresaburuaren interes legítimo soilik behar den. Bestalde, kategoria berezien datuak garatzen dira. Era berean, garrantzitsua da datu horien kontserbazioa eta zenbat denboran gorde daitezkeen kontuan izatea.

This work tries to give an explanation to the question that is asked with the data of the people who are candidates for a job. Moreover, it is explained in detail if it is a contract execution, a consent or if, only, the legitimate interest of the employer is necessary. On the other hand, a development is made in the case of special category data. In the same way, it is important to keep in mind the conservation of these data and for how long they can be kept.

Palabras clave: ejecución del contrato/ interés legítimo/ consentimiento/ incumplimiento/ datos biométricos/ datos afiliación sindical.

Gako-hitzak: kontratua gauzatzea/interes legítimo/adostasuna/ez-betetzea/datu biometrikoak/afiliazio sindikalaren datuak.

Keywords: execution of the contract/ legitimate interest/ consent/ breach/ biometric data/ union membership data.

- I. Abreviaturas**
- II. Objetivos**
- III. Metodología**
- IV. Introducción**
- V. Tratamiento de datos personales:**
 - a) Concepto*
 - b) Bases jurídicas para el tratamiento de datos personales*
 - c) Información respecto del tratamiento de datos personales*
 - d) Límites al tratamientos de datos*
- VI. Derechos de protección de datos en el ámbito laboral**
- VII. Principio de minimización y el impacto en la relación laboral**
- VIII. Consentimiento: ¿es necesario el consentimiento de la persona durante el proceso de selección?**
- IX. Selección del personal y redes sociales**
- X. Entrevista de trabajo**
- XI. Colaboración entre empresas (Agencias de colocación y empresas de selección)**
- XII. Decisiones automatizadas**
- XIII. La protección de datos personales en los procesos de selección de la plantilla: categorías especiales de datos**
 - a) Datos sobre afiliación sindical*
 - b) Datos biométricos*
 - c) Datos relativos a la salud*
 - d) Límites al tratamiento de categorías especiales de datos personales con el objeto de seleccionar a la plantilla*
 - e) Prohibición general de tratamiento*
 - f) Excepciones*
 - f.1) Consentimiento expícito del interesado*
 - f.2) Los datos personales públicamente manifestados por el interesado*
 - f.3) Fines médicos y sanitarias*
- XIV. Limitación del plazo de conservación**
- XV. Sanciones por incumplimiento en la Ley de Protección de Datos Personales, garantías y Derechos Digitales y Reglamento General de Protección de Datos.**
- XVI. Conclusiones**

I. Abreviaturas

AEPD Agencia Española de Protección de datos.

ET Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

FFJJ Fundamentos Jurídicos.

RGPD Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos).

LOPDGDD Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

LOLS Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical.

SSTC Sentencias del Tribunal Constitucional.

TS Tribunal Supremo.

TC Tribunal Constitucional.

TRLISOS Texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

II. Objetivos

La selección de personal es uno de los aspectos que ha visto uno de los mayores avances en los últimos años incorporando nuevas herramientas para contratar a los trabajadores. Por ello, se ha de tener en cuenta la protección de datos en la selección de personal, tomando como referencia la base jurídica que se ha de aplicar a la hora de proceder a su contratación y qué datos son de carácter personal.

Por ello, será imprescindible hacer un repaso a la legislación y jurisprudencia que afecta a la privacidad de los usuarios para conocer si esta clase de seguimiento a las personas candidatas es legítima y legal, o estamos rompiendo líneas de privacidad que, quizás, no deberían ser cruzadas. Y, sobre todo, las sanciones que se puede imponer por la comisión de algún incumplimiento de la normativa de protección de datos.

III. Metodología

El método utilizado para realizar este trabajo ha sido la revisión y consulta de fuentes de información, analizando su pluralidad, credibilidad así como su pertinencia para integrarlas a este trabajo.

En un primer momento se delimitó el tema así como los principales elementos a tener en cuenta, pues, existe un límite para hacer este trabajo. Para ello se realiza una búsqueda ya delimitada en lo que a la protección de datos en la selección de personal se refiere que permita la conceptualización de todas las ideas planteadas. De igual manera, se acudió a bases de datos, artículos de investigación, legislaciones, jurisprudencia y a artículos informativos, entre otros.

Posteriormente, se recopilaron los datos y se compilaron los documentos a fin de extraer los datos, las ideas principales, alcances y utilidad, con el fin de dar desarrollo a los objetivos propuestos, así como conocer la amplitud y diversidad temática a cerca de la protección de datos en la selección de personal.

Por último, se redactó el trabajo final tratando los temas más relevantes y aportando la máxima información posible para poder concluir la funcionalidad y utilidad de la protección de datos en la selección de personal.

IV. Introducción

El dato personal se define como toda aquella información respecto de una persona física identificada o identificable. Por poner algunos ejemplos es dato personal la vida académica, nombre y apellidos, número de identificación entre otros. Sin embargo, hay datos que puedan revelar el origen étnico o racial, las opiniones políticas o afiliación sindical los cuales el tratamiento de esos datos están prohibidos excepto en el ámbito laboral tal y como está regulado en el Reglamento de Protección de Datos.

En el caso del ámbito laboral la base jurídica es la ejecución del contrato laboral puesto que el consentimiento no es válido, pues, se produce un desequilibrio entre el interesado para el puesto y el responsable del tratamiento, algo que se desarrollara a lo largo de este trabajo. Sin embargo, el empresario tiene una serie de obligaciones legales pero hay que tener en cuenta que dispone de un interés legítimo en determinados casos. Ahora bien, el tratamiento de datos tiene límites durante la fase previa a la contratación.

Toda persona interesada para un puesto de trabajo en una empresa tiene los mismos derechos que el resto, es decir, también puede solicitar el derecho de acceso, de rectificación, el derecho de supresión, de limitación del tratamiento, portabilidad de los datos, de oposición, derecho a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas regulados en los artículos 15 y siguientes del Reglamento General de Protección de Datos.

Por otro lado, la base jurídica es la ejecución del contrato laboral, sin embargo, se ha de prestar especial consideración al principio de minimización de los datos regulado en el artículo 5 del RGPD dispone que los datos personales adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en relación con los fines para los que son tratados.

Del mismo modo, a lo largo de este trabajo se hace mención a las entrevistas de trabajo, colaboración entre empresas, es decir, agencias de colocación y empresas de selección, decisiones automatizadas, datos biométricos, sobre afiliación sindical etc. Además, es importante saber que ocurre con los datos en caso de no contratación, pues, en este supuesto es necesario el consentimiento de la persona candidata para el tratamiento futuro de los datos, como es, por ejemplo, la incorporación a una bolsa de trabajo excepto que el empresario pueda demostrar un interés legítimo. En caso contrario, todos esos datos extraídos del currículum han de ser destruidos y se tiene que suprimir así como bloquear todos esos datos personales.

En caso de incumplimiento de la normativa de protección de datos tanto la ley española como la europea tiene prevista una batería de infracciones y sanciones que pueden ser impuestas al infractor.

V. Tratamiento de datos personales:

a. Concepto

En primer lugar, en virtud de lo dispuesto en el artículo 4.1 del Reglamento de Protección de Datos, en adelante RGPD el cual define dato personal como *“toda aquella información sobre una persona física identificada o identificable”*. Por ejemplo, es dato personal datos que pueden asociarse a una persona física como es el nacimiento, matrimonio, domicilio entre otros. Asimismo, información numérica, alfabética, gráfica, fotográfica, acústica u otros. A lo anterior se ha de añadir datos sobre la infancia, sobre la vida académica, profesional o laboral, sobre hábitos de vida y consumo, relaciones personales o creencias religiosas las creencias religiosas e ideologías¹.

Pero, sobre todo, son datos personales los nombres y apellidos, número de identificación, datos de localización, un identificador en línea, elementos propios de la identidad física, fisiológica, genética, psíquica, económica, cultural o social. Del mismo modo, se consideran datos personales las evaluaciones y apreciaciones relativas a una persona en concreto².

Igualmente, conforme lo dispuesto en el artículo 9.1 del RGPD quedan totalmente prohibidos el tratamiento de datos *“que revelen el origen étnico o racial, las opiniones políticas, las convicciones religiosas o filosóficas, o la afiliación sindical, y el tratamiento de datos genéticos, datos biométricos dirigidos a identificar de manera unívoca a una persona física, datos relativos a la salud o datos relativos a la vida sexual o las orientaciones sexuales de una persona física”*. Por lo tanto, el tratamiento de datos de carácter personal está prohibido.

Ahora bien, el apartado 1 no se aplicará cuando sea requerido para el cumplimiento de las obligaciones así como el ejercicio de derechos específicos del responsable del tratamiento o del propio interesado en el ámbito laboral, de la seguridad social así como la protección social en todo lo regulado en el Derecho de la Unión de los Estados Miembros o Convenio Colectivo (artículo 9.2 RGPD).

Por otro lado, se ha de prestar especial consideración a lo dispuesto en el artículo 4.2 del RGPD el cual define tratamiento como *“cualquier operación o conjunto de operaciones realizadas sobre datos personales o conjuntos de datos personales, ya sea por procedimientos automatizados o no, como la recogida, registro, organización, estructuración, conservación, adaptación o modificación, extracción, consulta, utilización, comunicación por transmisión, difusión o cualquier otra forma de habilitación de acceso, cotejo o interconexión, limitación, supresión o destrucción”*.

Por último, no se considera tratamiento de datos regulado en el RGPD y a la Ley de Protección de Datos y Garantías de Derechos Digitales, en adelante LOPDGDD cuando se realice en el ejercicio de actividades ya sean personales o domésticas conforme lo dispuesto en el artículo 2.2 c) del RGPD.

¹ Agencia Española de Protección de Datos. (18 de mayo de 2021). Recuperado el 18 de julio de 2022, de la-proteccion-de-datos-en-las-relaciones-laborales: <https://www.aepd.es/es/documento/la-proteccion-de-datos-en-las-relaciones-laborales.pdf>

² Óp. Cit. Agencia Española de Protección de Datos. (18 de mayo de 2021). Recuperado el 18 de julio de 2022...

Además, para que se pueda aplicar la normativa respecto de la protección de datos tiene que estar presente los datos de carácter personal y se ha de disponer de tratamiento de datos personales³.

Por consiguiente, el empresario tiene enorme cantidad de información respecto de las personas trabajadoras, datos en referencia a la identidad, titulación, estado civil, descendencia, salud y la evaluación del desarrollo de las funciones. Del mismo modo, el Comité de empresa tendrá derecho a ser informado y consultado por el empresario sobre aquellas cuestiones que puedan afectar a los trabajadores, así como sobre la situación de la empresa y la evolución del empleo en la misma (artículo 64.1 ET), copia básica de los contratos (artículo 8.3 ET). Por ello, se ha de establecer mecanismos que protejan los datos de las personas trabajadoras de un uso no deseable de los mismos por parte del empresario o de los representantes de los trabajadores⁴. La Sentencia nº 142/1993 del Tribunal Constitucional de 22 de abril de 1993⁵ dispone que “*no vulnera el derecho a la intimidad el derecho de información de los representantes de los trabajadores (art. 8.3 ET [RCL 1995, 997]) consistente en la obtención de la copia básica del contrato en la que aparece el salario del trabajador, aunque reconoció que el salario es claramente un dato de carácter personal*”. Asimismo, la Sentencia nº88/1985 y 204/1997 del Tribunal Constitucional disponían que “*nada legitima que quienes presten servicios en organizaciones empresariales por cuenta y bajo la dependencia de sus titulares deban soportar despojos transitorios o limitaciones injustificadas de sus Derechos Fundamentales y libertades públicas, que tienen un valor central y nuclear en el sistema jurídico constitucional*”.

En definitiva, la celebración de un contrato no implica privar de Derechos Fundamentales que la Constitución le reconoce como ciudadano puesto que las empresas no son mundos estancos del resto de la sociedad ni la libertad de empresa (artículo 38 CE). Se trata de legitimar que los trabajadores soporten limitaciones de tales Derechos (SSTC 88/1995 y 204/1997)⁶.

Como corolario, son datos excesivos para valorar la capacidad profesional del candidato o para el normal desarrollo de la prestación de trabajo. En relación al proceso de selección, el objetivo deben responder los datos del solicitante de empleo es estrictamente la valoración de la aptitud así como capacidad profesional del candidato⁷.

b. Bases jurídicas para el tratamiento de datos personales

En primer lugar, el responsable del tratamiento ha de contar con una base jurídica que le legitime. Sin embargo, en el ámbito laboral, la base jurídica más importante es la ejecución del contrato de trabajo ya que el consentimiento del afectado no es válido en tanto en cuanto se produce un desequilibrio entre el interesado y el responsable del

³ Mercader Uguina, Jesús Rafael. Protección De Datos Y Garantía De Los Derechos Digitales En Las Relaciones Laborales. 3a ed., Francis-Lefebvre, 2019 (libro electrónico).

⁴ García-Núñez Serrano, Francisca. *La regulación sobre protección de datos personales su incidencia en el ámbito laboral*. 2000. Aranzadi.

⁵ (Tribunal Constitucional Sentencia nº 142/1993 de 22 de abril de 1993).

⁶ Óp. Cit. García-Núñez Serrano, Francisca. *La regulación sobre protección de datos personales su incidencia en el ámbito laboral...*

⁷ Tascón López, Rodrigo. *El tratamiento por la empresa de los personales de los trabajadores ¿un problema resuelto o caído en el olvido?* León, 2005. Aranzadi.

tratamiento. Por lo tanto, esa posición de desequilibrio se han de tomar todas las medidas y, en concreto, el respeto a los principios de proporcionalidad y de limitación de la finalidad. En este mismo sentido afirma el Considerando 40 del RGPD que *“los datos personales deben ser tratados con el consentimiento del interesado o sobre alguna otra base legítima establecida conforme a Derecho, ya sea en el presente Reglamento o en virtud de otro Derecho de la Unión o de los Estados miembros a que se refiera el presente Reglamento, incluida la necesidad de cumplir la obligación legal aplicable al responsable del tratamiento o la necesidad de ejecutar un contrato en el que sea parte el interesado o con objeto de tomar medidas a instancia del interesado con anterioridad a la conclusión de un contrato”*.

Sobre todo hay que tener en cuenta lo que manifiesta el Grupo de Trabajo respecto de la protección de Datos del artículo 29 (GT 29) *“Es muy poco probable que el consentimiento constituya una base jurídica para el tratamiento de datos en el trabajo, a no ser que los trabajadores puedan negarse sin consecuencias adversas [...] Salvo en situaciones excepcionales, los empresarios tendrán que basarse en otro fundamento jurídico distinto del consentimiento, como la necesidad de tratar los datos para su interés legítimo. Sin embargo, un interés legítimo en sí mismo no es suficiente para primar sobre los derechos y libertades de los trabajadores”*⁸.

La Sentencia nº 817/2017 del Tribunal Supremo, Sala de lo Social de 2 de febrero de 2017 manifiesta que han de cumplirse tres requisitos o condiciones. En su texto literal matiza que *“En efecto, de conformidad con la doctrina de este Tribunal, la constitucionalidad de cualquier medida restrictiva de derechos fundamentales viene determinada por la estricta observancia del principio de proporcionalidad. A los efectos que aquí importan, basta con recordar que para comprobar si una medida restrictiva de un derecho fundamental supera el juicio de proporcionalidad, es necesario constatar si cumple los tres requisitos o condiciones siguientes: si tal medida es susceptible de conseguir el objetivo propuesto (juicio de idoneidad); si, además, es necesaria, en el sentido de que no exista otra medida más moderada para la consecución de tal propósito con igual eficacia (juicio de necesidad); y, finalmente, si la misma es ponderada o equilibrada, por derivarse de ella más beneficios o ventajas para el interés general que perjuicios sobre otros bienes o valores en conflicto (juicio de proporcionalidad en sentido estricto) [SSTC 66/1995, de 8 de mayo, FJ 5; 55/1996, de 28 de marzo, FFJJ 6, 7, 8 y 9; 207/1996, de 16 de diciembre, FJ 4 e), y 37/1998, de 17 de febrero]”*⁹.

Por ello, el tratamiento de los datos de cada persona por parte de un empresario es lícito, siempre y cuando, sea requerida para la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte o bien para la aplicación del mismo empresario para tomar las medidas precontractuales que sean necesarias (artículo 6.1 b) RGPD). El Tribunal Constitucional señaló en su Sentencia nº 39/2016 3 de marzo de 2016 *“en el ámbito laboral el consentimiento del trabajador pasa, (...) como regla general a un segundo plano pues el consentimiento se entiende implícito en la relación negocial, siempre que el tratamiento de datos de carácter personal sea necesario para el mantenimiento y el cumplimiento del contrato firmado por las partes”*¹⁰.

⁸ «Comisión Europea.» s.f. Grupo de Trabajo respecto de la protección de Datos del artículo 29 . 30 de agosto de 2022. <https://ec.europa.eu/newsroom/article29/items>

⁹ (Tribunal Supremo Sentencia nº 817/2017 2 de febrero de 2017).

¹⁰ (Tribunal Constitucional Sentencia nº 39/2016 de 3 de marzo de 2016).

Asimismo, el tratamiento de datos es legítimo para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento (artículo 6.1 c) RGPD).

Por otro lado, la obligación legal es una base jurídica la cual acepta que el tratamiento de datos necesario para cumplir todo aquello que este regulado en la ley o por un convenio colectivo. A la anterior también se puede añadir la base jurídica del interés legítimo que persigue el responsable del tratamiento o por un tercero, siempre y cuando no predominen los intereses o los Derechos y Libertades Fundamentales del interesado que necesiten la protección de datos personales (artículo 6.1 f) RGPD). El Comité Europeo de Protección de Datos emitió su opinión en relación a este punto, su texto literal manifiesta lo siguiente: *“En caso de que un empresario pretenda invocar un interés legítimo [artículo 7, letra f)], la finalidad del tratamiento debe ser legítima; el método elegido o la tecnología específica deben ser necesarios, proporcionados y aplicados de la manera menos intrusiva posible, y el empresario deberá poder demostrar que se han adoptado las medidas adecuadas para garantizar un equilibrio con los derechos y libertades fundamentales de los trabajadores [...] Estas limitación podrían: a) ser geográficas (por ejemplo, control únicamente en lugares específicos; debe prohibirse el control en zonas sensibles como lugares religiosos y, por ejemplo, zonas de aseos y salas de descanso), b) estar orientadas a datos (por ejemplo, los archivos electrónicos personales y las comunicaciones no deben ser controlados), y c) ser temporales (por ejemplo, muestreo en lugar de control continuo)”*¹¹.

c. Información respecto del tratamiento de datos personales

En virtud de lo dispuesto en los artículos 13 y 14 del RGPD el responsable del tratamiento ha de informar a la plantilla de forma concisa, transparente, inteligible y de fácil acceso así como con un lenguaje claro y sencillo respecto del tratamiento de datos. Es más, el Grupo de Trabajo del artículo 29 disponía que *“La información facilitada a un interesado no debe contener lenguaje o terminología de naturaleza excesivamente legal, técnica o especializada, y deben evitarse expresiones indefinidas como «podría», «algunos», «frecuentemente» y «posible”*¹². La información es el contenido esencial del derecho a la protección de datos así como componen la garantía de la persona afectada puesto que permite conocer qué datos son tratados respecto de una persona, con quién los comparte el empresario, los derechos de los afectados, que se explicarán con posterioridad¹³. Sobre todo, es necesaria la adopción de la información por capas, es decir, la primera capa es la información básica y la segunda capa se detallan los datos mencionados en la anterior capa.

¹¹ «Comité Europeo de Protección de Datos.» s.f. *Grupo de Trabajo del artículo 29*. 31 de agosto de 2022. https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/who-we-are_es

¹² «Comisión Europea.» 11 de abril de 2018. *Guidelines on Transparency under Regulation 2016/679 (wp260rev.01)*. 20 de julio de 2022.. <https://ec.europa.eu/newsroom/article29/items/622227>

¹³ Óp. Cit. «Comisión Europea.» 11 de abril de 2018. *Guidelines on Transparency under Regulation 2016/679*

d. Límites al tratamientos de datos

En primer lugar, el tratamiento de datos personales ocurre durante la fase previa a la contratación, es decir, en el proceso de selección para un puesto de trabajo concreto. En consecuencia, se ha de prestar especial consideración a las siguientes precauciones¹⁴:

- ✓ El tratamiento de datos mientras se realiza el proceso de selección no se exige el consentimiento de la persona candidata. Es decir, la base jurídica que se tiene en cuenta es lo regulado en el artículo 6.1 b) del RGPD el cual dispone que “*el tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte o para la aplicación a petición de este de medidas precontractuales*”. Asimismo se ha de tener en cuenta lo dispuesto en el Considerando 44 del mismo cuerpo legal, que en su texto literal matiza que “*el tratamiento debe ser lícito cuando sea necesario en el contexto de un contrato o de la intención de concluir un contrato*”.
- ✓ Se puede disponer de impresos tipo para formalizar el currículo así como de un procedimiento para entregar a todas las personas candidatas. Esto es importante para informar de forma adecuada y para definir el tipo de datos que se van a tratar, establecer las medidas de seguridad etc.
- ✓ Si se realiza algún anuncio o convocatoria pública deberá de incluir la información del artículo 13 del RGPD.
- ✓ Si el currículum ha sido presentado por la persona candidata han de fijarse los procedimientos de información que pueda suponer un acuse o confirmación de que se conocen las condiciones del tratamiento. El deber de información ha de realizarse mediante una serie de medios que acrediten el cumplimiento. Asimismo, se ha de conservar mientras dure el tratamiento de los datos de las personas afectadas. La empresa siempre es responsable de la custodia de los documentos entregados por la persona candidata. Si se pierde todos esos documentos la empresa comete una infracción del RGPD, es decir, estaría vulnerando los principios de integridad y confidencialidad.

Como corolario, se puede pedir datos importantes para desarrollar un puesto de trabajo y no información de forma indiscriminada. Por ello, siempre ha de respetarse los principios de minimización y limitación de la finalidad.

Los tratamientos de datos para fines distintos exigen una base distinta como puede ser el consentimiento, obligación legal o un interés legítimo¹⁵.

La Sentencia nº 7922/2000 del Tribunal Supremo Sala de lo Contencioso de 31 de octubre de 2000 dispone que “*se considera datos personales las imprevisiones o*

¹⁴ Óp. Cit. *Agencia Española de Protección de Datos*. (18 de mayo de 2021). Recuperado el 18 de julio de 2022...

¹⁵ Óp. Cit. *Agencia Española de Protección de Datos*. (18 de mayo de 2021). Recuperado el 18 de julio de 2022...

valoraciones subjetivas de quienes llevan a cabo el proceso de selección por lo que debe garantizarse la transparencia en el tratamiento de esos datos, incluyendo la posibilidad del ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, oposición y supresión”.

Por otro lado, los empresarios suelen solicitar el informe de la vida laboral de todas las personas candidatas durante el proceso de selección de la plantilla. Por ello, se ha de tener en cuenta lo que a continuación se indica:¹⁶

- ✓ La empresa no tiene legitimación para obtener el informe de la vida laboral directamente de la Seguridad Social.
- ✓ El consentimiento no es una base jurídica válida, pues el candidato no es libre. Es más, la propia empresa puede acreditar un interés legítimo para solicitar el informe de la vida laboral. Únicamente, para confirmar la experiencia que la persona candidata haya reflejado en su solicitud.
- ✓ El informe que se entregue al empresario no es necesario que sea completo sino que podrá ser adaptado al interés legítimo que el empresario pueda demostrar, es decir, se estaría hablando de principio de minimización de datos.

Como ya se explicará más adelante, el incumplimiento del derecho del tratamiento de los datos tiene como consecuencia la imposición de una infracción de las reguladas en el artículo 83.5 b) del RGPD, pudiendo ser sancionada. Las empresas se les pueden imponer una multa administrativa de 20.000.000 euros o una cuantía equivalente al 4% como máximo del volumen de negocio anual global, comparando con el ejercicio financiero anterior, punto que se explicará con más detalle.

VI. Derechos de protección de datos en el ámbito laboral¹⁷

Los derechos que se aplican en el ámbito laboral son los que están regulados en los artículos 15 y siguientes del RGPD. Por ello, los trabajadores pueden ejercer sus derechos ante el responsable de tratamiento que corresponda. Los derechos que pueden ser ejercidos por cualquier trabajador son los que a continuación se indican:

- ✓ Derecho de acceso (artículo 15 RGPD): el trabajador o persona candidata tiene derecho a conocer el tratamiento de datos que se está llevando a cabo y, por lo tanto, tiene el derecho a conocer como se está produciendo el tratamiento. Todas las personas que ejerzan este derecho pueden solicitar una copia de los datos personales.
- ✓ Derecho de rectificación (artículo 16 RGPD): Cualquier trabajador o persona candidata tiene la posibilidad de solicitar este derecho los datos que sean inexactos o incompletos.

¹⁶ Óp. Cit. *Agencia Española de Protección de Datos*. (18 de mayo de 2021). Recuperado el 18 de julio de 2022...

¹⁷ Óp. Cit. *Agencia Española de Protección de Datos*. (18 de mayo de 2021). Recuperado el 18 de julio de 2022...

- ✓ Derecho de supresión (artículo 17 RGPD): la plantilla o la persona candidata tiene la posibilidad de suprimir los datos personales los cuales son las siguientes situaciones:
 - Cuando los datos personales ya no se requieran relativos con los fines para los que fueron recogidos o tratados de otro modo.
 - Cuando la base jurídica para el tratamiento de datos sea el consentimiento y el trabajador lo retire.
 - Cuando el tratamiento de datos sea ilícito.
 - En el caso de que la persona trabajadora se oponga al tratamiento de datos que no sean necesarios para el cumplimiento así como ejecución del contrato de trabajo.
 - Cuando los datos personales han de ser suprimidos en cumplimiento de una obligación legal.

Tanto este caso como el anterior los datos han de bloquearse. El bloqueo de datos “*consiste en la identificación y reserva de los mismos, adoptando medidas técnicas y organizativas, para impedir su tratamiento, incluyendo su visualización, excepto para la puesta a disposición de los datos a los jueces y tribunales, el Ministerio Fiscal o las Administraciones Públicas competentes, en particular de las autoridades de protección de datos, para la exigencia de posibles responsabilidades derivadas del tratamiento y solo por el plazo de prescripción de las mismas. Transcurrido ese plazo deberá procederse a la destrucción de los datos*” (artículo 32.2 LOPDGDD).

- ✓ Derecho a la limitación del tratamiento (artículo 18 RGPD): El artículo 4.3 del RGPD define limitación del tratamiento como “*el marcado de los datos de carácter personal conservados con el fin de limitar su tratamiento en el futuro*”. Por consiguiente, la plantilla puede ejercer sus derechos ante el empresario cuando se esté frente a una:
 - Inexactitud:
 - Ilícitud
 - Cuando los datos personales ya no son requeridos para los fines del tratamiento
 - Oposición
- ✓ Derecho a la portabilidad de los datos (artículo 20 RGPD): El trabajador tiene el derecho a recibir todos aquellos datos personales que le incumban facilitados a un responsable del tratamiento y transmitirlos a otro responsable del tratamiento sin que en ningún caso impida el responsable inicial su facilitación. Esto se ocurrirá cuando el tratamiento se ejecute por medios automatizados.
- ✓ Derecho de oposición (artículo 21 RGPD): Los trabajadores pueden ejercer su derecho frente la empresa la cual estará obligada a dejar de tratar los datos excepto que se acrediten motivos legítimos que predomine sobre los intereses, derechos y libertades de todos los trabajadores. Asimismo, para la formulación, el ejercicio o la defensa de las reclamaciones.

- ✓ Derecho a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas (artículo 22 RGPD): Este derecho procura que el afectado no sea objeto de una decisión basada en el tratamiento automatizado de sus datos. Este derecho se incluye la elaboración de perfiles que puedan tener efectos jurídicos en él o le pueda afectar de forma similar.

VII. Principio de minimización y el impacto en la relación laboral

En esta ocasión, la base jurídica es la ejecución del contrato laboral. No obstante, el empresario puede conocer los datos personales de la plantilla ya que el principio de minimización de datos exhorta que los datos personales “*sean adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en relación con los fines para los que son tratados*” conforme lo dispuesto en el artículo 5 RGPD.

Por consiguiente, el empresario puede tener derecho a conocer los datos personales necesarios para el desarrollo de la relación laboral. Por ejemplo, podría conocer los datos que se expondrán a continuación, aunque es, únicamente, ejemplificativo y no limitativo:¹⁸

- Nombre y apellidos de la persona trabajadora
- Sexo
- Número de DNI, número de identificación de extranjero y número de afiliación a la Seguridad Social
- Nacionalidad
- Discapacidad
- Fecha de nacimiento

Sin embargo, esos datos son importantes para hacer frente a las obligaciones empresariales como son los actos de encuadramiento de afiliación, alta y cotización de la Seguridad Social para, así, comprobar que el trabajador cumple con todos los requisitos para poder celebrar el contrato. No obstante, hay datos que no son imprescindibles para ejecutar un contrato como es, el nombre de usuario en las redes sociales o en servicios de mensajería o portales de internet. Por ello, el empresario deberá de hacer uso de una base jurídica distinta a la ejecución del contrato como puede ser el interés legítimo. Aunque el empresario ha de acreditar esa base jurídica teniendo presente los principios de ponderación y proporcionalidad. De la misma manera, hay que examinar las características de la relación laboral para, así, ver qué datos son necesarios para cumplir con ese contrato y cuáles no son necesarios. Por consiguiente, se habla de datos personales aquellos que permiten a la empresa localizar a las personas trabajadoras y contactar con ellas como son el domicilio, el correo electrónico, el número de teléfono o la cuenta bancaria. En términos generales, el empresario ha de tener alguna forma de contacto con la plantilla así como es imprescindible que el trabajador facilite alguna forma de contacto¹⁹.

¹⁸ Óp. Cit. *Agencia Española de Protección de Datos*. (18 de mayo de 2021). Recuperado el 18 de julio de 2022...

¹⁹ Óp. Cit. *Agencia Española de Protección de Datos*. (18 de mayo de 2021). Recuperado el 18 de julio de 2022...

En este punto se ha de prestar especial consideración a lo manifestado por el Tribunal Supremo en su Sentencia nº 4086/2015, de 21 de septiembre de 2015 Sala de lo Social el cual dispone que “a).- *La celebración de un contrato de trabajo no implica la privación -para el trabajador- de los derechos que la Constitución le reconoce como ciudadano, así como tampoco la libertad de empresa - art. 38 CE - justifica que los empleados «hayan de soportar limitaciones injustificadas de sus derechos fundamentales, porque el ejercicio de las facultades organizativas del empresario no puede traducirse en la producción de resultados inconstitucionales, lesivos de los derechos fundamentales del trabajador», de forma que los derechos fundamentales del trabajador» son prevalentes y constituyen un «límite infranqueable» no sólo a facultades sancionadoras del empresario, sino también a sus facultades de organización y de gestión, tanto causales como discrecionales*”²⁰.

En definitiva, se ha de examinar cada caso la base jurídica que puede tener el contrato laboral, el consentimiento, una obligación legal o el interés legítimo del empresario.

VIII. Consentimiento: ¿es necesario el consentimiento de la persona durante el proceso de selección?

En primer lugar, el consentimiento se define como toda manifestación de voluntad libre, específica, informada e inequívoca por la que este acepta, ya sea mediante una declaración o una clara acción afirmativa, el tratamiento de datos personales que le conciernen (artículo 6.1 LOPDGDD).

Por un lado, el tratamiento de los datos personales es lícito cuando sea necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte o para aplicación a petición de este de medidas precontractuales (artículo 6.1 b) RGPD). Además, se ha de diferenciar entre el tratamiento de los datos personales para facilitar o adoptar las medidas precontractuales necesarias (artículo 6.1 b) RGPD) y la admisión de tratar datos personales a efectos de contratación de personal (artículo 88.1 RGPD).

En el ámbito laboral se distingue en el proceso de selección de las personas trabajadoras y el precontrato laboral, es decir, el compromiso de ambas partes para celebrar un contrato laboral. Asimismo, ambas fases anteriores a la contratación tienen consecuencias jurídicas distintas con el trabajador seleccionado y el demandante de empleo²¹.

Por otro lado, es importante prestar especial consideración a Recomendación núm. R (89) 2, de 18 de enero de 1989, del Comité de Ministros del Consejo de Europa a los Estados miembros, sobre la protección de los datos de carácter personal con fines de empleo en el cual se explica que la expresión de “fines de empleo” han de referirse a las relaciones entre “trabajadores y empresario en materia de reclutamiento de los

²⁰ (Tribunal Supremo Sentencia nº 4086/2015 21 de septiembre de 2015)

²¹ De Val Tena, Ángel Luis. «Asociación Española de Derecho del Trabajo.» 17 de abril de 2020. *La Protección de Datos Personales en los procesos de selección de los trabajadores; en particular, aquellos datos especialmente sensibles*. 11 de agosto de 2022. [https://www.aedtss.com/wp-content/uploads/dl/N119/06%20La%20protecci%C3%B3n%20de%20datos%20personales%20en%20los%20procesos%20de%20selecci%C3%B3n%20de%20trabajadores_%20en%20particular,%20aquellos%20datos%20especialmente%20sensibles%20\(De%20Val%20Tena\).%20](https://www.aedtss.com/wp-content/uploads/dl/N119/06%20La%20protecci%C3%B3n%20de%20datos%20personales%20en%20los%20procesos%20de%20selecci%C3%B3n%20de%20trabajadores_%20en%20particular,%20aquellos%20datos%20especialmente%20sensibles%20(De%20Val%20Tena).%20)

trabajadores”. Igualmente, la Recomendación CM/Rec (2015) 5, de 1 de abril de 2015, del Comité de Ministros del Consejo de Europa, relativa al tratamiento de datos personales en el entorno laboral, el cual relata en el mismo sentido que la anterior Recomendación *“la relación entre empleadores y empleados en relación con la contratación”, se considera que la redacción del artículo 6.1.b) RGPD “es clara y solventa toda discrepancia al respecto”, concluyendo que “no es preciso el consentimiento para la aplicación de medidas precontractuales adoptadas a petición del interesado”*²².

La licitud de la obtención así como el tratamiento de datos personales en relación con las medidas precontractuales consta de dos requisitos; por un lado, que ese tratamiento sea necesario y, por otro, que se lleve a cabo por la solicitud del propio interesado. O dicho de otra forma el tratamiento se considera necesario a la hora de ejecutar un contrato el cual no requiere el consentimiento del interesado mientras que el tratamiento para la adopción de medidas precontractuales que si exige el consentimiento del interesado. Por lo tanto, conforme lo dicho por CRUZ VILLALÓN no se puede interpretar el artículo 6.1 b) del RGPD en el sentido de que está permitido al mismo empresario *“obtener y tratar esos datos por propia iniciativa sin el correlativo consentimiento del trabajador”*²³.

El tratamiento de datos es lícito cuando el interesado otorgue su consentimiento para uno o varios fines específicos (artículo 6.1 a) RGPD tal y como se explicará con posterioridad. No obstante, siempre ha de tenerse presente el artículo 5.1 c) del RGPD el cual dispone que *“los datos personales serán adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en relación con los fines para los que son tratados”*²⁴.

Sin embargo, hay casos en los que el interesado otorga su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales con uno o varios fines específicos. Como regla general, el consentimiento del interesado es garante de la licitud respecto del tratamiento de sus datos personales conforme lo dispuesto en el artículo 6.1 a) del RGPD, es decir, para que este tratamiento sea lícito los datos personales requieren del consentimiento del interesado²⁵.

Del mismo modo, el Considerando 32 del RGPD dispone que *“El consentimiento debe darse mediante un acto afirmativo claro que refleje una manifestación de voluntad libre, específica, informada, e inequívoca del interesado de aceptar el tratamiento de datos de carácter personal que le conciernen, como una declaración por escrito, inclusive por medios electrónicos, o una declaración verbal”*. Por ello, el consentimiento del interesado ha de emanar de una declaración escrita o de una acción afirmativa del interesado y, por lo tanto, se excluye el consentimiento tácito.

²² «Consejo de Europa.» 1 de abril de 2015. Recomendación CM/Rec (2015)5, de 1 de abril de 2015, del Comité de Ministros del Consejo de Europa relativa al tratamiento de datos personales en el entorno laboral. 30 de julio de 2022. https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805c3f7a

²³ Cruz Villalón, Jesús. Cruz Villalón, Jesús. *Protección de datos personales del trabajador en el proceso de contratación: facultades y límites de la actuación del empleador*. Albacete: Bomarzo, 2019. P.27

²⁴ Óp. Cit. De Val Tena, Ángel Luis. «Asociación Española de Derecho del Trabajo.» 17 de abril de 2020. *La Protección de Datos Personales en los procesos de selección de los trabajadores...*

²⁵ Óp. Cit. De Val Tena, Ángel Luis. «Asociación Española de Derecho del Trabajo.» 17 de abril de 2020. *La Protección de Datos Personales en los procesos de selección de los trabajadores...*

Tal es así, que el consentimiento ha de darse para cada actividad de tratamiento realizados con el mismo o los mismos fines y en el caso de que el tratamiento tenga varias finalidades se tiene que dar el consentimiento; de forma específica e inequívoca²⁶. Sin embargo, la persona trabajadora podrá retirar el consentimiento en cualquier momento, tal y como señala el artículo 7.3 del RGPD. Es más, tal precepto continúa diciendo que *“La retirada del consentimiento no afectará a la licitud del tratamiento basada en el consentimiento previo a su retirada. Antes de dar su consentimiento, el interesado será informado de ello. Será tan fácil retirar el consentimiento como darlo”*.

No obstante, en el ámbito de las relaciones laborales el consentimiento no se otorga de forma válida y libre puesto que en la mayoría de casos el tratamiento de datos de los trabajadores la base jurídica ha de ser otra diferente²⁷. Esto se debe a que se esta ante una relación de subordinación entre el trabajador y el empresario dado que para garantizar que el consentimiento se ha otorgado libremente *“este no debe constituir un fundamento jurídico válido para el tratamiento de datos de carácter personal en un caso concreto en el que exista un desequilibrio claro entre el interesado y el responsable del tratamiento”*²⁸.

Por consiguiente, el consentimiento de interesado está definido en el artículo 4.11 del RGPD el cual dispone que *“toda manifestación de voluntad libre, específica, informada e inequívoca por la que el interesado acepta, ya sea mediante una declaración o una clara acción afirmativa, el tratamiento de datos personales que le conciernen”*. Por ello, el legislador ha de constituir una serie de garantías que aseguren la validez jurídica del consentimiento para, así, reconocer la licitud de tratamiento de los datos personales²⁹. La definición del Reglamento tiene cuatro requisitos para que el consentimiento prestado sea válido. Por ello, la AEPD sigue las recomendaciones del Consejo de Europa en materia de protección de datos y así ha indicado en numerosos informes y resoluciones. En definitiva, el consentimiento, sigue la definición de RGPD, por lo tanto, ha de ser: 1.º) Libre, lo que supone que deberá haber sido obtenido sin la intervención de vicio alguno del consentimiento en los términos regulados por el Código Civil; 2.º) Específico, es decir, referido a una determinada operación de tratamiento y para una finalidad determinada, explícita y legítima del responsable del tratamiento; 3.º) Inequívoco, lo que implica que no resulta admisible deducir el consentimiento de los meros actos realizados por el afectado (consentimiento presunto), siendo preciso que exista expresamente una acción u omisión que implique la existencia del consentimiento; y 4.º) informado, lo que exige que el afectado conozca con anterioridad al tratamiento la existencia de éste y las finalidades para las que se produce³⁰.

²⁶ Óp. Cit. De Val Tena, Ángel Luis. «Asociación Española de Derecho del Trabajo.» 17 de abril de 2020. *La Protección de Datos Personales en los procesos de selección de los trabajadores...*

²⁷ Óp. Cit. De Val Tena, Ángel Luis. «Asociación Española de Derecho del Trabajo.» 17 de abril de 2020. *La Protección de Datos Personales en los procesos de selección de los trabajadores...*

²⁸ Considerando 43 del Reglamento General de Protección de Datos.

²⁹ Óp. Cit. De Val Tena, Ángel Luis. «Asociación Española de Derecho del Trabajo.» 17 de abril de 2020. *La Protección de Datos Personales en los procesos de selección de los trabajadores...*

³⁰ Desdendentado Bonete, Aurelio y Ana Belén Muñoz Ruiz. *Protección de datos y contrato de trabajo*. Madrid, 2011. Revista de Justicia Laboral nº 46/2011.

Además, teniendo en cuenta el Reglamento y la legislación española es de considerar que el interesado consintió el tratamiento de los datos conforme lo dispuesto en el artículo 7.1 del RGPD por lo que una declaración escrita y firmada es el mejor medio de prueba. Asimismo, debe ser clara y precisa identificando los fines específicos por lo que se otorga tal consentimiento. Es importante añadir a lo anterior, para procurar que se funde el tratamiento de los datos en el consentimiento de la persona afectada para una variedad de objetivos, es necesario que refleje de forma específica e inequívoca que el consentimiento se otorga para todas ellas conforme lo dispuesto en el artículo 6.2 LOPDGDD³¹.

Es más, según lo regulado en el artículo 7.2 del RGPD el cual manifiesta que “*si el consentimiento del interesado se da en el contexto de una declaración escrita que también se refiera a otros asuntos, la solicitud de consentimiento se presentará de tal forma que se distinga claramente de los demás asuntos, de forma inteligible y de fácil acceso y utilizando un lenguaje claro y sencillo*”. Igualmente, se ha de tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 7.4 RGPD el cual matiza que al evaluar si el consentimiento se otorga de forma libre se ha de tener presente si la ejecución de un contrato incluida la prestación de un servicio, se supedita al consentimiento de tratamiento de datos personales los cuales no son requeridos para ejecutar un contrato. En el mismo sentido señala el artículo 6.3 LOPDGDD en el que no se supedita “*la ejecución del contrato a que el afectado consienta el tratamiento de los datos personales para finalidades que no guarden relación con el mantenimiento, desarrollo o control de la relación contractual*”³².

En caso de incumplimiento de lo anteriormente expuesto, se estaría ante una infracción muy grave. Es más, tal y como está regulado en el artículo 72.1 b) y c) de la LOPDGDD “*el tratamiento de datos personales sin que concurra alguna de las condiciones de licitud del tratamiento establecidas en el artículo 6 del Reglamento (UE) 2016/679*” y “*el incumplimiento de los requisitos exigidos por el artículo 7 del Reglamento (UE) 2016/679 para la validez del consentimiento*”.

Por otro lado, se ha de tener especial consideración a los artículos 1262 y siguientes del Código Civil respecto de la validez del consentimiento. Es decir, se considera nulo si el consentimiento ha sido prestado con error, violencia, intimidación o dolo; con esto lo que se pretende es garantizar que el tratamiento de los datos personales sean lícitos. En definitiva, el consentimiento que otorga la persona interesada no puede medir el error, la violencia, la intimidación o el dolo. O dicho de otra forma ha de ser un consentimiento que este otorgado con voluntad libre, específica, informada e inequívoca. Para ello, ha de ser una declaración expresa que pueda probarse o una acción afirmativa³³.

Como corolario, se necesita una cláusula de consentimiento para el tratamiento de los datos que podría emplearse a modo de ejemplo el que se encuentra en el Anexo I.

³¹ Óp. Cit. De Val Tena, Ángel Luis. «Asociación Española de Derecho del Trabajo.» 17 de abril de 2020. *La Protección de Datos Personales en los procesos de selección de los trabajadores...*

³² Óp. Cit. De Val Tena, Ángel Luis. «Asociación Española de Derecho del Trabajo.» 17 de abril de 2020. *La Protección de Datos Personales en los procesos de selección de los trabajadores...*

³³ Óp. Cit. De Val Tena, Ángel Luis. «Asociación Española de Derecho del Trabajo.» 17 de abril de 2020. *La Protección de Datos Personales en los procesos de selección de los trabajadores...*

IX. Selección del personal y redes sociales

Las personas tanto candidatas como trabajadoras no se encuentran en la obligación de dar permiso para que el empresario indague en sus perfiles de las redes sociales, durante el proceso de selección ni tampoco durante la ejecución del contrato³⁴.

El Dictamen 2/2017 sobre el tratamiento de datos en el trabajo del Grupo de Trabajo de Artículo 29 dispone que el acceso a un perfil en una red social de un candidato tiene que ser público, es decir, el perfil de la persona candidata ha de ser público. Sin embargo, el empresario no puede realizar un tratamiento de datos con esos datos obtenidos sino cuenta con una base jurídica válida. La indagación en tales perfiles, únicamente, si está relacionado con un fin profesional. Es más, dicho tratamiento solo será posible cuando se acredite que sea necesaria y pertinente para desarrollar un trabajo. Igualmente, la plantilla ha de ser informada del tratamiento³⁵.

A lo anterior se ha de añadir que el empresario no está legitimado para solicitar amistad a todas las personas candidatas para que proporcionen los contenidos de sus perfiles³⁶. Del mismo modo, tampoco puede solicitar amistad con tales personas información que el mismo trabajador o candidato comparte con otros a través de su perfil en redes sociales³⁷.

Como corolario, el empresario no ha de efectuar un tratamiento de los datos que haya obtenido por esta vía si no tiene una base jurídica válida³⁸. Para ello, el empresario ha de informar a la persona trabajadora así como demostrar que el tratamiento es necesario y pertinente para desarrollar su trabajo. Por lo tanto, la empresa no está legitimada para solicitar amistad a las personas candidatas para que proporcionen acceso a esos contenidos que tienen en sus perfiles³⁹. Además, no por el hecho de que sean perfiles públicos quiere decir que se pueden tratar para fines propios del empresario, es decir, ha de haber un fundamento legal para tal tratamiento como, puede ser, por ejemplo el interés legítimo⁴⁰.

X. Entrevista de trabajo

El candidato a un empleo contesta a diversas preguntas durante una entrevista laboral. Sin embargo, se ha de tener en cuenta que esas contestaciones no equivalen a un consentimiento para el tratamiento de los datos personales.

³⁴ Óp. Cit. *Agencia Española de Protección de Datos*. (18 de mayo de 2021). Recuperado el 18 de julio de 2022...

³⁵ «Comisión Europea.» 8 de junio de 2017. *Grupo de Trabajo del Artículo 29*. 20 de julio de 2022. <https://ec.europa.eu/newsroom/article29/items/610169>

³⁶ Óp. Cit. «Comisión Europea.» 8 de junio de 2017. *Grupo de Trabajo del Artículo 29*. 20 de julio de 2022...

³⁷ Óp. Cit. *Agencia Española de Protección de Datos*. (18 de mayo de 2021). Recuperado el 18 de julio de 2022...

³⁸ Royo Pérez, Victoria. *Diez claves sobre protección de datos en el trabajo*. 20 de mayo de 2021. Noticias Jurídicas.

³⁹ Óp. Cít. Royo Pérez, Victoria. *Diez claves sobre protección de datos en el trabajo*...

⁴⁰ Loza Corcera, María. *Tratamiento de datos personales en el ámbito laboral: análisis del Dictamen 2/2017 GT artículo 29*. 12 de septiembre de 2017. Legal Today.

En definitiva, todos los datos que se obtenga por esta vía no se podrán realizar un tratamiento sino se dispone de una base jurídica, es decir, datos requeridos para la ejecución de un contrato, interés legítimo o consentimiento⁴¹.

En segundo lugar, se ha de prestar atención la Sentencia de la Sala de lo Social nº 1799/2014 del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz de Tenerife de fecha de 7 de abril de 2014 la cual relata que *“el hecho de someter a una candidata a preguntas familiares y personales totalmente ajenas al trabajo a desempeñar, sea cual sea el lugar de prestación de los servicios (pues ya había manifestado su disponibilidad a desplazarse), supone una conducta discriminatoria, puesto que la trabajadora se ha visto obligada revelar sus planes familiares y datos médicos pertenecientes a su más estricta intimidad, innecesarios para una gestión de personal responsable y respetuosa con la dignidad del empleado”*⁴².

Como corolario, si hay un empresario que solicita datos de carácter personal en procesos de selección puede constituir discriminaciones que atentan contra el principio de igualdad. Es más, puede incurrir en una infracción muy grave regulada en el artículo 16.1.c) del Texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, en adelante TRLISOS, el cual dispone que *“Solicitar datos de carácter personal en los procesos de selección o establecer condiciones, mediante la publicidad, difusión o por cualquier otro medio, que constituyan discriminaciones para el acceso al empleo por motivos de sexo, origen, incluido el racial o étnico, edad, estado civil, discapacidad, religión o convicciones, opinión política, orientación sexual, afiliación sindical, condición social y lengua dentro del Estado”*.

XI. Colaboración entre empresas (Agencias de colocación y empresas de selección)

En ocasiones, los empresarios no realizan la selección de personal sino que emplean agencias de colocación, es decir, empresas que se dedican a la selección del personal o Empresas de Trabajo Temporal. Las agencias de colocación y empresas de selección de personal serán las encargadas del tratamiento cuando hayan suscrito un contrato con la empresa que busca trabajadores y la que determinará los fines y medios de ese tratamiento. La función de esas empresas es localizar a personas potenciales para prestar servicios en la empresa principal. Sin embargo, emplean como base lo dispuesto en el artículo 6.1 b) del RGPD debido a que es necesario para celebrar un contrato y no el consentimiento. En su texto literal manifiesta que *“el tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte o para la aplicación a petición de este de medidas precontractuales”*. Por lo tanto, en el momento que desaparece la base jurídica que legitima el tratamiento de datos ha de ser destruido o devuelto⁴³.

⁴¹ Óp. Cit. Agencia Española de Protección de Datos. (18 de mayo de 2021). Recuperado el 18 de julio de 2022...

⁴² (Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz de Tenerife Sentencia nº 1799/2014 de 7 de abril de 2014)

⁴³ Óp. Cit. Agencia Española de Protección de Datos. (18 de mayo de 2021). Recuperado el 18 de julio de 2022...

Por otro lado, las empresas de colocación y empresas de selección de personal cuando contacten con los candidatos de forma previa a disponer de ofertas de empleo concretas. Por ello, se considerarán responsable de tratamiento de los datos de la persona candidata. Igualmente, es importante señalar que las empresas de trabajo temporal son responsables del tratamiento dado que son empleadoras directas de la plantilla⁴⁴.

Como corolario, es necesario el consentimiento del futuro trabajador para que la empresa en la que solicita un puesto ceda sus datos a otras empresas del grupo⁴⁵.

XII. Decisiones automatizadas

Como se sabe, el Reglamento prohíbe el tratamiento automatizado incluyendo la elaboración de perfiles en el caso de que se produzca efectos jurídicos en el mismo interesado o le pueda afectar de forma significativa. Sin embargo, esas decisiones se llevarán a cabo cuando sean requeridas para la celebración o ejecución de un contrato⁴⁶. Las Directrices sobre decisiones individuales automatizadas y elaboración de perfiles a los efectos del Reglamento 2016/679 del Grupo de Trabajo del Artículo 29 manifiesta que *“es admisible la decisión automatizada en procesos de selección con numerosos candidatos para realizar una primera criba excluyendo a quienes incumplen alguna condición o requisito esencial, como la ausencia de titulación suficiente”*⁴⁷.

De otro lado, es importante prestar especial consideración a las decisiones basadas en algoritmos así como la elaboración de perfiles en el proceso de selección, siempre y cuando el resultado lesione los derechos fundamentales, el diseño del algoritmo ha de ser modificado. Además, en el procedimiento ha de estar regulado un mecanismo en la cual intervenga una persona en tanto en cuanto el afectado lo solicite así como un trámite para que el afectado pueda expresar su opinión y pueda impugnar si se diera el caso⁴⁸. El Considerando 71 del RGPD dispone que la persona afectada tenga el derecho a recibir alguna explicación de la decisión después de la evaluación. El responsable del tratamiento ha de garantizar que la supervisión de la decisión sea significativa para que se considere intervención humana.

Como corolario, conforme lo dispuesto en el artículo 35.3 del RGPD, el diseño y la implementación del algoritmo han de realizarse una evaluación de impacto⁴⁹.

⁴⁴ Óp. Cit. Agencia Española de Protección de Datos. (18 de mayo de 2021). Recuperado el 18 de julio de 2022...

⁴⁵ Óp. Cit. Agencia Española de Protección de Datos. (18 de mayo de 2021). Recuperado el 18 de julio de 2022...

⁴⁶ Óp. Cit. Agencia Española de Protección de Datos. (18 de mayo de 2021). Recuperado el 18 de julio de 2022...

⁴⁷ «Comisión Europea.» 6 de febrero de 2018. *Guidelines on Automated individual decision-making and Profiling for the purposes of Regulation 2016/679 (wp251rev.01)*. 24 de julio de 2022. <https://ec.europa.eu/newsroom/article29/items/612053>

⁴⁸ Óp. Cit. Agencia Española de Protección de Datos. (18 de mayo de 2021). Recuperado el 18 de julio de 2022...

⁴⁹ Óp. Cit. De Val Tena, Ángel Luis. «Asociación Española de Derecho del Trabajo.» 17 de abril de 2020. *La Protección de Datos Personales en los procesos de selección de los trabajadores...*

XIII. La protección de datos personales en los procesos de selección de la plantilla: categorías especiales de datos

a. Datos sobre afiliación sindical

La protección proviene del derecho fundamental a la libertad sindical. Es más, es un derecho que se proyecta sobre las personas trabajadoras puesto que les permite organizarse con la finalidad de promocionarse y defender sus intereses profesionales. Entre otras resoluciones, se ha de manifestar las sentencias del Tribunal Constitucional 132/2000, de 16 de mayo, 76/2001, de 26 de marzo, y 281/2005, de 7 de noviembre las cuales establecen que es un derecho fundamental de amplio contenido esencial y derecho así como facultades adicionales. Tal hecho está recogido en la Constitución Española la cual trae al derecho interno lo dispuesto en los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo nº 87 y 98 “*el derecho a fundar sindicatos y a afiliarse al de su elección*”. Esa afiliación no puede ser forzosa o imperativa, pues, tal y como establece el artículo 28.1 de la Constitución Española “*nadie podrá ser obligado a afiliarse a un sindicato*”. De igual forma, es importante señalar que el derecho a sindicarse es libre y por lo tanto, esos datos quedan reservados por el derecho a la intimidad o privacidad o vinculación a un sindicato. Únicamente, podrá conocer el sindicato elegido por la persona trabajadora en el que ha ingresado libremente. Toda la información de la persona trabajadora afiliada y el dato de la afiliación constarán en los archivos así como los ficheros del sindicato, sin que esos datos personales puedan comunicarse a terceros sin el consentimiento del interesado⁵⁰.

Sin embargo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 11.2 de la LOLS “*El empresario procederá al descuento de la cuota sindical sobre los salarios y a la correspondiente transferencia a solicitud del sindicato del trabajador afiliado y previa conformidad, siempre, de éste*”⁵¹. Es más, la persona trabajadora no tiene obligación de declarar su afiliación a un sindicato. En el caso de que un trabajador concreto desee abonar su cuota al sindicato por medio del descuento o retención en el recibo de salarios, puede autorizar al sindicato que solicite al empresario que descuente la cuantía que corresponda y a la transferencia a la cuenta de la organización sindical⁵².

Los datos de afiliación sindical es un dato sensible y, por ende, está protegido. El sindicato no puede solicitar el descuento al empresario directamente. Ahora bien, el sindicato tiene que tener el consentimiento expreso, libre e indubitado de la persona trabajadora para que el sindicato requiera al empresario el descuento de la cuota y para que el mismo empresario realice el descuento en la nómina del trabajador afectado. De esta forma, el empresario podrá demostrar que el trabajador consintió el tratamiento de sus datos personales (artículo 7.1 RGPD⁵³). En tal sentido, el informe nº 0434/2010 de la AEPD manifiesta que “*será necesario contar con el consentimiento expreso y por escrito del afiliado no solo para la comunicación al sindicato de los datos referidos al pago de la cuota sindical por parte del empresario, sino también para la comunicación*

⁵⁰ Óp. Cit. De Val Tena, Ángel Luis. «Asociación Española de Derecho del Trabajo.» 17 de abril de 2020. *La Protección de Datos Personales en los procesos de selección de los trabajadores...*

⁵¹ Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de libertad sindical.

⁵² Óp. Cit. De Val Tena, Ángel Luis. «Asociación Española de Derecho del Trabajo.» 17 de abril de 2020. *La Protección de Datos Personales en los procesos de selección de los trabajadores...*

⁵³ Artículo 7.1 RGPD “*Cuando el tratamiento se base en el consentimiento del interesado, el responsable deberá ser capaz de demostrar que aquel consintió el tratamiento de sus datos personales*”.

previa efectuada por el sindicato al empresario de su condición de afiliado que solicita el descuento en la nómina de la citada cuota”.

Todos los sindicatos pueden tratar los datos de afiliación de la plantilla que voluntaria y libremente deciden pertenecer a la misma asociación siempre y cuando *“en el ámbito de sus actividades legítimas y con las debidas garantías los datos personales no se comuniquen fuera de ellos sin el consentimiento de los interesados”* (artículo 9.2 d) del RGPD⁵⁴). Por lo tanto, cada sindicato es responsable del tratamiento de esos datos.

Como corolario, en el caso de que los datos de la afiliación sindical consten en una administración o entidad se les aplicará las normas reguladoras el derecho de acceso a la información pública⁵⁵. Tal es así, que se ha de acudir a lo regulado en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno *“el acceso únicamente se podrá autorizar en caso de que se contase con el consentimiento expreso y por escrito del afectado, a menos que dicho afectado hubiese hecho manifiestamente públicos los datos con anterioridad a que se solicitase el acceso”*. Sin embargo, es importante señalar que el consentimiento expreso del afectado no servirá para llevar a cabo el tratamiento de ese dato por quien o quienes lo conozcan. En tal sentido el artículo 9.1 de la LOPDGGD matiza que *“el solo consentimiento del afectado no bastará para levantar la prohibición del tratamiento de datos cuya finalidad principal sea identificar su ideología, afiliación sindical, religión, orientación sexual, creencias u origen racial o étnico”*.

b. Datos biométricos

En primer lugar, el artículo 4.14 del RGPD define dato biométrico como *“datos personales obtenidos a partir de un tratamiento técnico específico, relativos a las características físicas, fisiológicas o conductuales de una persona física que permitan o confirmen la identificación única de dicha persona, como imágenes faciales o datos dactiloscópicos”*. Este supuesto está encuadrado como categoría especial de datos personales los cuales identifican de forma unívoca a una persona concreta tal y como señala el artículo 9.1 del RGPD⁵⁶.

De igual manera, el Dictamen 4/2007, de 20 de junio, sobre el concepto de datos personales, adoptado por el GT29 definió como *“propiedades biológicas, características fisiológicas, rasgos de la personalidad o tics, que son, al mismo tiempo, atribuibles a una sola persona y mensurables, incluso si los modelos utilizados en la*

⁵⁴ Artículo 9.2 d) RGPD *“el tratamiento es efectuado, en el ámbito de sus actividades legítimas y con las debidas garantías, por una fundación, una asociación o cualquier otro organismo sin ánimo de lucro, cuya finalidad sea política, filosófica, religiosa o sindical, siempre que el tratamiento se refiera exclusivamente a los miembros actuales o antiguos de tales organismos o a personas que mantengan contactos regulares con ellos en relación con sus fines y siempre que los datos personales no se comuniquen fuera de ellos sin el consentimiento de los interesados”*.

⁵⁵ Óp. Cit. Agencia Española de Protección de Datos. (18 de mayo de 2021). Recuperado el 18 de julio de 2022...

⁵⁶ Artículo 9.1 RGPD *“Quedan prohibidos el tratamiento de datos personales que revelen el origen étnico o racial, las opiniones políticas, las convicciones religiosas o filosóficas, o la afiliación sindical, y el tratamiento de datos genéticos, datos biométricos dirigidos a identificar de manera unívoca a una persona física, datos relativos a la salud o datos relativos a la vida sexual o las orientación sexuales de una persona física”*.

*práctica para medirlos técnicamente implican un cierto grado de probabilidad*⁵⁷. En este mismo sentido manifiesta el Considerando 51 del RGPD “*El tratamiento de fotografías no debe considerarse sistemáticamente tratamiento de categorías especiales de datos personales, pues únicamente se encuentran comprendidas en la definición de datos biométricos cuando el hecho de ser tratadas con medios técnicos específicos permita la identificación o la autenticación unívocas de una persona física*”.

Actualmente, se dispone de sistemas que emplean información o datos biométricos los cuales pueden analizar aspectos físicos así como morfológicos de la persona⁵⁸ o por la valoración de sus comportamientos o habilidades⁵⁹. Estos sistemas son útiles para garantizar el acceso de las personas trabajadoras a las dependencias o el empleo de los equipamientos ya sea por la actividad que desarrolla o por el valor así como las consecuencias de los medios materiales pueden ocasionar para el trabajador o para terceros. En definitiva, el objetivo principal es que no haya una suplantación de identidad de una persona física⁶⁰.

Para realizar el reconocimiento biométrico, es necesario captar a través de un sensor específico para cada técnica biométrica, uno o varios rasgos específicos de la persona, y su transformación en una secuencia numérica, conformando una plantilla que queda registrada en una base de datos concreta. Tras esto, el empleo del sistema biométrico requerirá comparar la plantilla y la muestra biométrica. Por lo tanto, la recogida y el tratamiento posterior pueden poner en riesgo los derechos fundamentales de las personas trabajadoras puesto que de todos esos datos puede descubrir otras informaciones que pertenecen a la privacidad de una persona. Tal es así, que las Sentencias del Tribunal Constitucional 66/1995, de 8 de mayo, 55/1996, de 28 de marzo, 207/1996, de 16 de diciembre, y 37/1998, de 17 de febrero manifiestan que “*para comprobar si una medida restrictiva de un derecho fundamental supera el juicio de proporcionalidad, es necesario constatar si cumple los tres requisitos o condiciones siguientes: si tal medida es susceptible de conseguir el objetivo propuesto (juicio de idoneidad); si, además, es necesaria, en el sentido de que no exista otra medida más moderada para la consecución de tal propósito con igual eficacia (juicio de necesidad); y, finalmente, si la misma es ponderada o equilibrada, por derivarse de ella más beneficios o ventajas para el interés general que perjuicios sobre otros bienes o valores en conflicto (juicio de proporcionalidad en sentido estricto)*”.

c. Datos relativos a la salud

El artículo 4.15 del RGPD define datos relativos a la salud como aquellos “*datos personales relativos a la salud física o mental de una persona física, incluida la prestación de servicios de atención sanitaria, que revelen información sobre su estado de salud*”. Igualmente, el Considerando 35 del mismo texto legal relata que se han de incluir “*todos los datos relativos al estado de salud del interesado que dan información sobre su estado de salud física o mental pasado, presente o futuro. Se incluye la*

⁵⁷ Dictamen 4/2007, de 20 de junio, sobre el concepto de datos personales, adoptado por el GT29. 20 de junio de 2007. 27 de agosto de 2022. https://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2007/wp136_es.pdf

⁵⁸ Huellas dactilares, patrones de la mano, reconocimiento facial, características de la retina, geometría del iris, rasgos de la voz, estructuras venosas, pulsaciones, ondas cerebrales o estado de atención.

⁵⁹ Comprobación de su escritura, firma o presión sobre las teclas del ordenador.

⁶⁰ Óp. Cit. De Val Tena, Ángel Luis. «Asociación Española de Derecho del Trabajo.» 17 de abril de 2020. *La Protección de Datos Personales en los procesos de selección de los trabajadores...*

información sobre la persona física recogida con ocasión de su inscripción a efectos de asistencia sanitaria, o con ocasión de la prestación de tal asistencia, de conformidad con la Directiva 2011/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (1); todo número, símbolo o dato asignado a una persona física que la identifique de manera unívoca a efectos sanitarios; la información obtenida de pruebas o exámenes de una parte del cuerpo o de una sustancia corporal, incluida la procedente de datos genéticos y muestras biológicas, y cualquier información relativa, a título de ejemplo, a una enfermedad, una discapacidad, el riesgo de padecer enfermedades, el historial médico, el tratamiento clínico o el estado fisiológico o biomédico del interesado, independientemente de su fuente, por ejemplo un médico u otro profesional sanitario, un hospital, un dispositivo médico, o una prueba diagnóstica in vitro”.

En concreto, al estar analizando los datos relativos a la salud, para ello, se ha de acudir a la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica. Y, sobre todo, interesa tener presente lo dispuesto en el artículo 2.1 en el cual *“La dignidad de la persona humana, el respeto a la autonomía de su voluntad y a su intimidad orientarán toda la actividad encaminada a obtener, utilizar, archivar, custodiar y transmitir la información y la documentación clínica”*. Y ratifica en el artículo 7.1 del mismo cuerpo legal, en relación al derecho a la intimidad el cual dispone que *“Toda persona tiene derecho a que se respete el carácter confidencial de los datos referentes a su salud, y a que nadie pueda acceder a ellos sin previa autorización amparada por la Ley”*.

En el ámbito laboral, la salud de la persona trabajadora puede disminuir su rendimiento o imposibilitar la prestación de servicios de forma temporal. Ahora bien, la empresa tiene la posibilidad de prevenir el desarrollo de enfermedades o patologías o bien verificar el estado de salud de la persona trabajadora⁶¹. Por lo tanto, el empresario tiene un poder de dirección en el que podrá verificar el estado de salud de la persona trabajadora conforme lo dispuesto en el artículo 20.4 del ET que literalmente señala que *“El empresario podrá verificar el estado de salud del trabajador que sea alegado por este para justificar sus faltas de asistencia al trabajo, mediante reconocimiento a cargo de personal médico”*. Es más, dicho precepto continúa diciendo *“La negativa del trabajador a dichos reconocimientos podrá determinar la suspensión de los derechos económicos que pudieran existir a cargo del empresario por dichas situaciones”*; como pueden ser las mejoras voluntarias respecto de las prestaciones económicas del sistema de la Seguridad Social. Es decir, el empresario puede realizar todos los controles médicos adicionales a los realizados por el sistema público, entidades gestoras y colaboradoras de la Seguridad Social por medio del servicio médico de la propia empresa o el recurso a servicios sanitarios externos⁶². Sin embargo, conforme lo dispuesto en la Sentencia del Tribunal Supremo nº recurso 249/2016 del 25 de enero de 2018 no es posible realizar pruebas diagnósticas que no tengan los fines relacionados con el estado de salud.

⁶¹ Óp. Cit. De Val Tena, Ángel Luis. «Asociación Española de Derecho del Trabajo.» 17 de abril de 2020. *La Protección de Datos Personales en los procesos de selección de los trabajadores...*

⁶² Óp. Cit. Agencia Española de Protección de Datos. (18 de mayo de 2021). Recuperado el 18 de julio de 2022...

Además de lo anterior, se ha de prestar especial consideración a la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales, de ahora en adelante LPRL, el cual en su artículo 22.1.I, el empresario está obligado a garantizar a las personas trabajadoras *“a su servicio la vigilancia periódica de su estado de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo”*. Todas aquellas medidas de vigilancia y control de la salud de la plantilla se realizarán a través del personal sanitario competente, formación y capacidad acreditada (artículo 22.6 LPRL⁶³).

Por consiguiente, tal vigilancia, únicamente, se podrá realizar cuando el trabajador otorgue su consentimiento. Sin embargo, tiene como excepción tal y como señala el artículo 22.1 LPRL, *“previo informe de los representantes de los trabajadores, los supuestos en los que la realización de los reconocimientos sea imprescindible para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores o para verificar si el estado de salud del trabajador puede constituir un peligro para el mismo, para los demás trabajadores o para otras personas relacionadas con la empresa o cuando así esté establecido en una disposición legal en relación con la protección de riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad”*.

Concretamente, en la protección los datos de la salud de la plantilla, es una información que han sido obtenida en los procesos de vigilancia de su salud con una finalidad preventiva y, por lo tanto, no puede emplearse *“con fines discriminatorios ni en perjuicio del trabajador”* (artículo 22.4 LPRL)⁶⁴. En el caso de las fases de intermediación, selección y colocación se realizan test psicotécnicos y psicológicos con los cuales se pueden conocer datos personales sensibles. Cruz Villalón ha manifestado que *“han de entenderse como ilícitos, por carente de fundamento y desproporcionados, cuando por su contenido pretendan efectuar una indagación en la personalidad del demandante de empleo, no justificada de manera objetiva y solvente como requisito necesario a efectos del desarrollo de la actividad profesional para la que va a ser contratada”*⁶⁵.

d. *Límites al tratamiento de categorías especiales de datos personales con el objeto de seleccionar a la plantilla*

En definitiva, la protección que se otorga a los datos personales sensibles en relación con los derechos y libertades fundamentales se realiza en un régimen propio para su tratamiento el cual puede tener riesgos para los derechos y libertades. Por ello, se ha de diferenciar el tratamiento de las categorías especiales de datos que deben de ser tratados salvo que haya situaciones delimitadas y contempladas por el legislador así como los Estados miembros pueden legislar disposiciones relativas a la protección de datos con el objetivo de adaptar el Reglamento. En definitiva, se han regulado de forma explícita excepciones a la prohibición general de tratamiento, sobre todo cuando el interesado otorgue su consentimiento explícito⁶⁶. Sin embargo, se ha de aplicar los

⁶³ Artículo 22.6 LPRL *“Las medidas de vigilancia y control de la salud de los trabajadores se llevarán a cabo por personal sanitario con competencia técnica, formación y capacidad acreditada”*.

⁶⁴ Óp. Cit. Agencia Española de Protección de Datos. (18 de mayo de 2021). Recuperado el 18 de julio de 2022...

⁶⁵ Cruz Villalón, Jesús. Cruz Villalón, Jesús. *Protección de datos personales del trabajador en el proceso de contratación: facultades y límites de la actuación del empleador*. Albacete: Bomarzo, 2019. P.53

⁶⁶ Óp. Cit. De Val Tena, Ángel Luis. «Asociación Española de Derecho del Trabajo.» 17 de abril de 2020. *La Protección de Datos Personales en los procesos de selección de los trabajadores...*

requisitos particulares del tratamiento, los principios generales y las condiciones de licitud del tratamiento (Considerando 51 RGPD).

e. Prohibición general de tratamiento

En primer lugar, se ha de tener presente el Considerando 75 del RGPD “*Los riesgos para los derechos y libertades de las personas físicas, de gravedad y probabilidad variables, pueden deberse al tratamiento de datos que pudieran provocar daños y perjuicios físicos, materiales o inmateriales*”. Sobre todo, en los casos de que los datos personales revelen el origen étnico o racial, las opiniones políticas, la religión o creencias filosóficas, la militancia en sindicatos así como el tratamiento de datos genéticos, datos en relación a la salud o datos sobre la vida sexual.

Por lo tanto, teniendo como referencia el artículo 9.1 RGPD el cual dispone que “*Quedan prohibidos el tratamiento de datos personales que revelen el origen étnico o racial, las opiniones políticas, las convicciones religiosas o filosóficas, o la afiliación sindical, y el tratamiento de datos genéticos, datos biométricos dirigidos a identificar de manera unívoca a una persona física, datos relativos a la salud o datos relativos a la vida sexual o las orientación sexuales de una persona física*”. Sin embargo, el apartado 2 del mismo precepto señala que casos no será de aplicación lo dispuesto en el apartado 1. No obstante, el legislador interviene según lo dispuesto en la normativa comunitaria por el llamamiento a enervar o concretar en los casos de tratamiento excepcional o bien el reenvío, de datos para el tratamiento de datos genéticos, datos biométricos o datos relativos a la salud, a los ordenamientos de los Estados miembros para mantener o introducir condiciones adicionales, inclusive limitaciones (artículo 9.4 RGPD).

En definitiva, conforme lo dispuesto en el artículo 9.1 LOPDGDD la prohibición, “*a fin de evitar situaciones discriminatorias*”, comprende un conjunto de datos que evidencian los rasgos de la persona o de su determinación social, cuyo conocimiento puede producir una serie de prejuicios sociales. Es decir, pueden situar en una posición de desventaja en muchos ámbitos, entre los que incluimos las relaciones de empleo o de trabajo, e incluso puede ser contraria a la dignidad de la persona (art. 10.1 CE)⁶⁷.

f. Excepciones

En virtud de lo dispuesto en el Considerando 52 del RGPD se autorizan excepciones a la prohibición de tratar categorías especiales de datos personales “*cuando lo establezca el Derecho de la Unión o de los Estados miembros y siempre que se den las garantías apropiadas, a fin de proteger datos personales y otros derechos fundamentales, cuando sea en interés público...*”.

La categoría de datos sensibles una categoría con identidad propia y del que surgen dos subcategorías⁶⁸:

- El tratamiento de datos cuyo objetivo principal es identificar su origen racial o étnico, ideología, afiliación sindical, religión, creencias u orientación sexual, respecto de los que “*el solo consentimiento del afectado no bastará para*

⁶⁷ Óp. Cit. Agencia Española de Protección de Datos. (18 de mayo de 2021). Recuperado el 18 de julio de 2022...

⁶⁸ Óp. Cit. Agencia Española de Protección de Datos. (18 de mayo de 2021). Recuperado el 18 de julio de 2022...

levantar la prohibición” (artículo 9.1 LOPDGDD). Ahora bien, no impide el tratamiento de los supuestos regulados en el artículo 9.2 RGPD.

- El tratamiento de datos genéticos, datos biométricos y datos relativos a la salud, al que se aplican todos los supuestos excepcionales incluyendo el consentimiento del interesado del artículo 9.2 RGPD que levantan la prohibición general. Los Estados miembros podrán mantener o introducir condiciones adicionales, inclusive limitaciones, con respecto al tratamiento de datos genéticos, datos biométricos o datos relativos a la salud (artículo 9.4 RGPD).

f.1) Consentimiento explícito del interesado

El consentimiento se define el artículo 4.11 del RGPD como *“toda manifestación de voluntad libre, específica, informada e inequívoca por la que el interesado acepta, ya sea mediante una declaración o una clara acción afirmativa, el tratamiento de datos personales que le conciernen”*.

El RGPD no define el consentimiento explícito⁶⁹ y para ello hay que acudir a lo dispuesto por el GT29 en sus «Directrices sobre el consentimiento en el sentido del Reglamento (UE) 2016/679 el cual señala que *“el término explícito se refiere a la forma en la que el consentimiento se expresa por parte del interesado. Significa que el interesado debe dar una declaración expresa de consentimiento. Una manera obvia de asegurar que el consentimiento es explícito sería que se confirmara de forma expresa el consentimiento a través de una declaración escrita. Cuando sea apropiado, el Responsable del tratamiento podría asegurarse que el interesado firma una declaración escrita con el objetivo de eliminar cualquier posible duda y potenciar la falta evidencia en el futuro”*⁷⁰. Igualmente, el GT29 proporciona una serie de ejemplos consentimiento explícito que pueden ser la confirmación del consentimiento a través de una declaración escrita, la firma de una declaración escrita, el envío de una declaración rellenando un formulario electrónico, el envío de una declaración vía correo electrónico, la subida de un documento firmado escaneado, el uso de firma electrónica⁷¹.

La prohibición de tratamiento de la categoría especial de dato personal no se aplica tal y como está regulado en el artículo 9.2 a) del RGPD *“el interesado dio su consentimiento explícito para el tratamiento de dichos datos personales con uno o más de los fines especificados, excepto cuando el Derecho de la Unión o de los Estados miembros establezca que la prohibición mencionada en el apartado 1 no puede ser levantada por el interesado”*. Ahora bien, se ha de tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 9.1 de la LOPDGDD con el objetivo de evitar situaciones discriminatorias *“el solo consentimiento del afectado no bastará para levantar la prohibición del tratamiento de datos cuya finalidad principal sea identificar su ideología, afiliación sindical, religión, orientación sexual, creencias u origen racial o étnico”*.

⁶⁹ Mercader Uguina, Jesús Rafael. Protección De Datos Y Garantía De Los Derechos Digitales En Las Relaciones Laborales. 3a ed., Francis-Lefebvre, 2019 (libro electrónico).

⁷⁰ «European Data Protection Board.» 4 de mayo de 2020. *Directrices 5/2020 sobre el consentimiento en el sentido del Reglamento (UE) 2016/679*. 31 de agosto de 2022. https://edpb.europa.eu/sites/default/files/files/file1/edpb_guidelines_202005_consent_es.pdf

⁷¹ Óp. Cit. ⁷¹ «European Data Protection Board.» 4 de mayo de 2020. *Directrices 5/2020 sobre el consentimiento en el sentido del Reglamento (UE) 2016/679*. 31 de agosto de 2022

En cuanto a los datos de afiliación sindical, la Sentencia del Tribunal Supremo Sala Civil del 12 de noviembre de 2015 nº recurso 899/2014⁷² el informe nº 0201/2010 de la AEPD⁷³ relatan que *“recogida y difusión de determinada información relativa a un determinado grupo de personas, elaborada de conformidad con determinados criterios dependiendo del tipo de lista negra en cuestión, que generalmente implica efectos adversos y perjudiciales para las personas incluidas en la misma, que pueden consistir en discriminar a un grupo de personas al excluirlas de la posibilidad del acceso a un determinado servicio o dañar su reputación”*.

f.2) Los datos personales públicamente manifestados por el interesado

En una excepción a la regla regulada en el artículo 9.1 del RGPD cuando el tratamiento de datos personales se han hecho públicos. Asimismo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 24 de noviembre de 2011 en su Asunto ASNEF C-468/10 y C-469/10 en el cual disponen que *“la gravedad de la lesión de los derechos fundamentales de la persona afectada por un tratamiento irregular de sus datos puede variar en función de que los datos figuren ya, o no, en fuentes accesibles al público”*.⁷⁴

El apartado 2 letra e) del artículo 9 del RGPD manifiesta que la prohibición de tratamiento de datos que pertenecen a la categoría especial no se ha de aplicar cuando *“el tratamiento se refiere a datos personales que el interesado ha hecho manifiestamente públicos”*. El concepto de manifiestamente público se define como aquello que se expresa, se revela o se muestra ese dato y de tal forma su titular sale del ámbito privado.

Sin embargo, Dictamen 757/2017, de 26 de octubre de 2017, del Consejo de Estado, sobre el Anteproyecto de Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal dispone que *“los datos hechos públicos de manera voluntaria por el interesado, se requiere cumplir una de las condiciones legales, al menos, para que el tratamiento sea lícito”*.

Del mismo modo, la Sentencia nº 91/2017 del Tribunal Supremo Sala Civil de 15 de febrero de 2017⁷⁵ en relación a una fotografía publicada en una red social y accesible a un público en general en el cual dispone que no hay una autorización para que terceros reproduzcan en los medios de comunicación y las redes sociales no son accesibles para el público en general. La prestación de consentimiento para la publicación de una imagen propia en Internet conlleva el consentimiento para la difusión de esa imagen cuando tal difusión, por sus características, sea consecuencia natural del carácter accesible de los datos e imágenes publicados en internet.

En el mismo sentido, se señala la Sentencia nº 476/2018 del Tribunal Supremo Sala Civil del 20 julio de 2018 *“la inclusión de una imagen en un tuit equivale en buena medida a la inclusión en el propio tuit del enlace en que tal imagen se halla, lo que*

⁷² (Tribunal Supremo Sala Civil Sentencia nº recurso 899/2014 de 3 de marzo de 2016).

⁷³ (AEPD Informe Jurídico nº 0201/2010)

⁷⁴ Óp. Cit. Mercader Uguina, Jesús Rafael. Protección De Datos Y Garantía De Los Derechos Digitales En Las Relaciones Laborales....

⁷⁵ (Tribunal Supremo Sala Civil Sentencia nº 91/2017 de 15 de febrero de 2017).

puede considerarse como una “consecuencia natural” de la publicación consentida de la imagen en un determinado sitio web de acceso general”⁷⁶.

f.3) Fines médicos y sanitarias

Es importante prestar atención a que la prohibición de tratamiento de cualquier categoría especial de dato personal no se ha de aplicar cuando el tratamiento “*es requerido para fines de medicina preventiva o laboral, evaluación de la capacidad laboral del trabajador, diagnóstico médico, prestación de asistencia o tratamiento de tipo sanitario o social, o gestión de los sistemas y servicios de asistencia sanitaria y social, sobre la base del Derecho de la Unión o de los Estados miembros o en virtud de un contrato con un profesional sanitario*” (artículo 9.2 h) RGPD). Hay una excepción cuando es realizado por el profesional sujeto a la obligación de secreto profesional, o bajo su responsabilidad, de acuerdo con el Derecho de la Unión o de los Estados miembros o con las normas establecidas por los organismos nacionales competentes, o por cualquier otra persona sujeta a la obligación de secreto de acuerdo con el Derecho de la Unión o de los Estados miembros o de las normas establecidas por los organismos nacionales competentes (artículo 9.2 i) RGPD).

Además, el artículo 22.4 II LPRL dispone que “*El acceso a la información médica de carácter personal se limitará al personal médico y a las autoridades sanitarias que lleven a cabo la vigilancia de la salud de los trabajadores, sin que pueda facilitarse al empresario o a otras personas sin consentimiento expreso del trabajador*”.

XIV. Limitación del plazo de conservación

En primer lugar, los datos de carácter personal se tienen que mantener durante no más tiempo del necesario a los efectos de identificar a los interesados, en función de los objetivos del tratamiento⁷⁷. Por lo tanto, los datos personales se pueden conservar durante periodos más largos tal y como dispone en el artículo 5.e) del RGPD que su texto literal señala que “*los datos personales podrán conservarse durante periodos más largos siempre que se traten exclusivamente con fines de archivo en interés público, fines de investigación científica o histórica o fines estadísticos, de conformidad con el artículo 89, apartado 1, sin perjuicio de la aplicación de las medidas técnicas y organizativas apropiadas que impone el presente Reglamento a fin de proteger los derechos y libertades del interesado*”. El informe 0408/2010 de la AEPD ha señalado que no se puede establecer una enumeración de los periodos en que los datos han de estar conservados y bloqueados por las empresas⁷⁸.

Sin embargo, el periodo coincidirá con el tiempo requerido para la prescripción de las todas las acciones que se deriven de la relación jurídica que vincula al responsable con el interesado. Además, ese periodo ha de sumarse al tiempo durante el cual ha estado vigente la relación que sirve de base al tratamiento. Asimismo, se puede emplear los plazos establecidos en el artículo 4 de la LISOS, tanto la normativa laboral como la de Seguridad Social así como la de prevención de riesgos laborales regulan diversos plazos. A modo de ejemplo el RD 664/1997 sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos; RD 665/1997

⁷⁶ (Tribunal Supremo Sala Civil Sentencia nº 476/2018 de 20 julio de 2018).

⁷⁷ Óp. Cit. Mercader Uguina, Jesús Rafael. Protección De Datos Y Garantía De Los Derechos Digitales En Las Relaciones Laborales.

⁷⁸ (AEPD Informe Jurídico nº 0408/2010)

sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos; Real Decreto 396/2006 por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto; y Real Decreto 783/2001 por el que se aprueba el Reglamento sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes, establecen plazos muy amplios de conservación de la documentación que cabría entender que se proyectan en el ámbito de la protección de datos⁷⁹.

El artículo 34.9 del ET dispone que *“La empresa conservará los registros a que se refiere este precepto durante cuatro años y permanecerán a disposición de las personas trabajadoras, de sus representantes legales y de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social”*.

Sobre todo, es importante tener presente que en el momento que finaliza el proceso de selección si la persona candidata no es contratada desaparece la base jurídica para el tratamiento de datos. Como consecuencia, es necesario el consentimiento para un futuro tratamiento excepto que el empresario demuestre un interés legítimo. Por el contrario, se ha de destruir el currículum y proceder a la supresión así como el bloqueo de los datos personales⁸⁰.

XV. Sanciones por incumplimiento en la Ley de Protección de Datos Personales, garantías y Derechos Digitales y Reglamento General de Protección de Datos.

En virtud de lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 83 del RGPD señala que las infracciones con multas administrativas de 10.000.000 euros como máximo o, tratándose de una empresa, de una cuantía equivalente al 2 % como máximo del volumen de negocio total anual global del ejercicio financiero anterior, optándose por la de mayor cuantía:

- a) las obligaciones del responsable y del encargado a tenor de los artículos 8, 11, 25 a 39, 42 y 43;
- b) las obligaciones de los organismos de certificación a tenor de los artículos 42 y 43;
- c) las obligaciones de la autoridad de control a tenor del artículo 41, apartado 4.

Asimismo, el apartado 5 del mismo precepto del RGPD las infracciones de las disposiciones siguientes se sancionarán, de acuerdo con el apartado 2, con multas administrativas de 20.000.000 euros como máximo o, tratándose de una empresa, de una cuantía equivalente al 4 % como máximo del volumen de negocio total anual global del ejercicio financiero anterior, y siempre se optará por la de mayor cuantía:

- a) los principios básicos para el tratamiento, incluidas las condiciones para el consentimiento a tenor de los artículos 5, 6, 7 y 9;

⁷⁹ Óp. Cit. Mercader Uguina, Jesús Rafael. Protección De Datos Y Garantía De Los Derechos Digitales En Las Relaciones Laborales.

⁸⁰ Óp. Cit. Agencia Española de Protección de Datos. (18 de mayo de 2021). Recuperado el 18 de julio de 2022...

- b) los derechos de los interesados a tenor de los artículos 12 a 22;
- c) las transferencias de datos personales a un destinatario en un tercer país o una organización internacional a tenor de los artículos 44 a 49;
- d) toda obligación en virtud del Derecho de los Estados miembros que se adopte con arreglo al capítulo IX;
- e) el incumplimiento de una resolución o de una limitación temporal o definitiva del tratamiento o la suspensión de los flujos de datos por parte de la autoridad de control con arreglo al artículo 58, apartado 2, o el no facilitar acceso en incumplimiento del artículo 58, apartado 1.

Por lo expuesto, el artículo 83.6 del mismo texto legal dispone que el incumplimiento de las resoluciones de la autoridad de control a tenor del artículo 58, apartado 2, se sancionará de acuerdo con el apartado 2 del presente artículo con multas administrativas de 20.000. 000 EUR como máximo o, tratándose de una empresa, de una cuantía equivalente al 4 % como máximo del volumen de negocio total anual global del ejercicio financiero anterior, optándose por la de mayor cuantía.

En la LOPDGDD se regula el régimen sancionador entre los artículos 70 y ss. Por lo tanto, dependiendo de las infracciones habrá que calificarla de muy grave, grave y leve teniendo en consideración que la diferenciación que el Reglamento establece al fijar la cuantía de las sanciones⁸¹.

En esos preceptos aparece un listado de infracciones que son en forma de ejemplo. Las infracciones se pueden interrumpir con conocimiento del interesado del procedimiento sancionador, pudiéndose reiniciar el plazo de prescripción si el expediente sancionador se hubiese paralizado durante más de seis meses por causas no imputable al presunto infractor.

Por consiguiente, el RGPD establece diferentes sanciones administrativas. Dichas infracciones, como ya se ha manifestado con anterioridad, tiene multas de hasta 10 millones de euros o hasta el 2% de la facturación anual global. En cambio, el Reglamento prevé para otras infracciones los máximos de hasta 20 millones de euros o el 4% de la facturación global. Por ello, la vulneración de las reglas del consentimiento está sujeta a un mayor nivel de multas⁸².

⁸¹ Rubio Torrano, Enrique. *Del Reglamento europeo a la nueva Ley Orgánica de Protección de Datos*. 2018. Aranzadi.

⁸² Martínez Rojas, Ángela. *Principales aspectos del consentimiento en el Reglamento de protección de Datos de la Unión Europea*. 2016. Aranzadi.

XVI. Conclusiones

PRIMERO: Dato personal se define toda aquella información respecto de una persona física identificada o identificable. Puede ser dato personal, domicilio, información alfanumérica, fotográfica, nombre y apellidos, número de identificación entre otros (artículo 4.11 RGPD). Ahora bien, hay datos que están totalmente prohibidos como son aquellos que puedan revelar el origen étnico o racial, opiniones políticas, afiliación sindical, datos genéticos, datos biométricos conforme lo dispuesto en el artículo 9.1 del RGPD. En el ámbito laboral, el empresario tiene una cantidad ingente de información sobre la plantilla como son la identidad, titulación, estado civil o la evaluación del desarrollo de las funciones.

En cuanto a las bases jurídicas para el tratamiento de datos personales, el responsable del tratamiento deberá de contar con una base jurídica que le legitime. Por lo tanto, en el ámbito laboral podemos tener como base jurídica la ejecución de un contrato, la obligación legal pero también se puede estar un interés legítimo del empresario. Sin embargo, el consentimiento del afectado no sería válido puesto que hay un desequilibrio entre el interesado y el responsable del tratamiento.

Respecto a la información sobre del tratamiento de datos personales, la información es el contenido esencial del derecho a la protección de datos así como componen la garantía de la persona afectada puesto que da la posibilidad conoce qué datos son tratados respecto de una persona, con quién los comparte el empresario, los derechos de los afectados. Los tratamientos de datos para fines diferentes exigen una base distinta como puede ser el consentimiento, obligación legal o un interés legítimo, habrá que analizar caso por caso.

SEGUNDO: En cuanto a los derechos, se aplican los mismos derechos regulados en los artículos 15 y siguientes del RGPD como son el derecho de acceso, derecho de rectificación, derecho de supresión, derecho a la limitación del tratamiento, derecho a la limitación del tratamiento, derecho a la portabilidad de los datos, derecho de oposición y derecho a no ser objeto de decisiones automatizadas.

TERCERO: Los datos han de ser adecuados, pertinentes y limitados a los necesario en relación con los fines para lo que son tratados (artículo 5 RGPD). Los datos que se pueden conocer como por ejemplo nombre y apellidos de la persona trabajadora, sexo, DNI, nacionalidad, discapacidad, fecha de nacimiento. Se tiene que analizar la base jurídica que ha de tener el contrato de trabajo.

CUARTO: el tratamiento de los datos personales es lícito cuando sea necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte o para aplicación a petición de este de medidas precontractuales (artículo 6 RGPD). En el ámbito laboral, se distingue en el proceso de selección de las personas trabajadoras y el precontrato laboral, es decir, el compromiso de sendas partes para celebrar un contrato de trabajo. La licitud de la obtención así como el tratamiento de datos personales en relación con las medidas precontractuales consta de dos requisitos; de un lado que ese tratamiento sea necesario y, por otro, que se lleve a cabo por la solicitud del propio interesado. El tratamiento de datos es lícito cuando el afectado otorgue su consentimiento para uno o varios fines específicos (artículo 6.1 b) RGPD). En el ámbito de las relaciones laborales el consentimiento no se otorga de forma válida y libre puesto que en la mayoría de casos el tratamiento de datos de los trabajadores la base jurídica ha de ser otra diferente.

QUINTO: Las personas tanto candidatas como trabajadoras no se encuentran en la obligación de dar permiso para que el empresario indague en sus perfiles de las redes sociales, durante el proceso de selección ni tampoco durante la ejecución del contrato. A lo anterior se ha de añadir que el empresario no está legitimado para solicitar amistad a todas las personas candidatas para que proporcionen los contenidos de sus perfiles. En definitiva, el empresario no ha de efectuar un tratamiento de los datos que haya obtenido por esta vía si no tiene una base jurídica válida.

SEXTO: El candidato a un empleo contesta a diversas preguntas durante una entrevista laboral. Sin embargo, se ha de tener en cuenta que esas contestaciones no equivalen a un consentimiento para el tratamiento de los datos personales. Por consiguiente, todos los datos que se obtenga por esta vía no se podrán realizar un tratamiento sino hay una base jurídica para ello.

SÉPTIMO: Los empresarios emplean agencias de colocación, es decir empresas que están dedicadas a la selección del personal o empresas de trabajo temporal. Estas empresas son las encargadas del tratamiento cuando suscriban un contrato con las empresas que buscan personas trabajadoras.

OCTAVO: En primer lugar, el Reglamento prohíbe el tratamiento automatizado, incluyendo la elaboración de perfiles en el proceso de selección y siempre que no se lesione los derechos fundamentales el diseño del algoritmo deberá de ser modificado. En el procedimiento ha de estar regulado un mecanismo en la cual intervenga una persona en tanto en cuanto el afectado lo solicite así como un trámite para que el afectado pueda expresar su opinión y pueda impugnar si se diera el caso.

NOVENO: La protección proviene del derecho fundamental a la libertad sindical. Los datos de afiliación sindical es un dato sensible y, por ende, está protegido. El sindicato tiene que tener el consentimiento expreso, libre e indubitado de la persona trabajadora para que el sindicato requiera al empresario el descuento de la cuota y para que el mismo empresario realice el descuento en la nomina del trabajador afectado. Los datos biométricos son aquellos datos personales obtenidos de un tratamiento técnico específico en relación a las características, fisiológicas o conductuales de una persona física que permitan o confirmen la identificación única a una persona como son las imágenes faciales o datos dactiloscópicos (artículo 4.14 del RGPD). En definitiva, para realizar el reconocimiento biométrico, es necesario captar a través de un sensor específico para cada técnica biométrica, uno o varios rasgos específicos de la persona, y su transformación en una secuencia numérica, conformando una plantilla que queda registrada en una base de datos concreta. Tras esto, el empleo del sistema biométrico requerirá comparar la plantilla y la muestra biométrica. Por lo tanto, la recogida y el tratamiento posterior pueden poner en riesgo los derechos fundamentales de las personas trabajadoras puesto que de todos esos datos puede descubrir otras informaciones que pertenecen a la privacidad de una persona.

Los datos relativos a la salud se definen como aquellos datos en relación a la salud física o mental de una persona física incluyendo la prestación de servicios de atención sanitaria que revelen información respecto de su estado de salud. En el ámbito laboral, la salud de la persona trabajadora puede disminuir su rendimiento o imposibilitar la prestación de servicios de forma temporal. Ahora bien, la empresa tiene la posibilidad de prevenir el desarrollo de enfermedades o patologías o bien verificar el estado de salud de la persona trabajadora. Por consiguiente, el empresario tiene un poder de dirección en el que podrá verificar el estado de salud de la persona trabajadora. No

obstante, conforme lo dispuesto en la Sentencia del Tribunal Supremo nº recurso 249/2016 del 25 de enero de 2018 no es posible realizar pruebas diagnósticas que no tengan los fines relacionados con el estado de salud. Todas aquellas medidas de vigilancia y control de la salud de la plantilla se realizarán a través del personal sanitario competente, formación y capacidad acreditada (artículo 22.6 LPRL). Dicha vigilancia, únicamente, se podrá realizar cuando el trabajador otorgue su consentimiento.

La protección que se otorga a los datos personales sensibles en relación con los derechos y libertades fundamentales se realiza en un régimen propio para su tratamiento el cual puede tener riesgos para los derechos y libertades. En definitiva, se han regulado de forma explícita excepciones a la prohibición general de tratamiento, sobre todo cuando el interesado otorgue su consentimiento explícito.

Respecto a la prohibición general de tratamiento, se ha de tener en cuenta lo dispuesto en el Considerando 75 del RGPD *“Los riesgos para los derechos y libertades de las personas físicas, de gravedad y probabilidad variables, pueden deberse al tratamiento de datos que pudieran provocar daños y perjuicios físicos, materiales o inmateriales”*. La prohibición, *“a fin de evitar situaciones discriminatorias”*, comprende un conjunto de datos que evidencian los rasgos de la persona o de su determinación social, cuyo conocimiento puede producir una serie de prejuicios sociales. Hay una serie de excepciones a la prohibición de tratar categorías especiales de datos personales *“cuando lo establezca el Derecho de la Unión o de los Estados miembros y siempre que se den las garantías apropiadas, a fin de proteger datos personales y otros derechos fundamentales, cuando sea en interés público...”*.

El consentimiento se define como *toda manifestación de voluntad libre, específica, informada e inequívoca por la que el interesado acepta, ya sea mediante una declaración o una clara acción afirmativa, el tratamiento de datos personales que le conciernen* (artículo 4.11 del RGPD). Los datos personales públicamente manifestados por el interesado es una excepción a la regla estipulada en el artículo 9.1 del RGPD. Además, los datos para fines médicos y sanitarios se tiene que contar con lo dispuesto en el artículo 22.4 LPRL *“el acceso a la información médica de carácter personal se limitará al personal médico y a las autoridades sanitarias que lleven a cabo la vigilancia de la salud de los trabajadores, sin que pueda facilitarse al empresario o a otras personas sin consentimiento expreso del trabajador”*.

DÉCIMO: los datos de carácter personal se tienen que mantener durante no más tiempo del necesario a los efectos de identificar a los interesados, en función de los objetivos del tratamiento. Además, el periodo coincidirá con el tiempo necesario para la prescripción de las todas las acciones que se deriven de la relación jurídica que vincula al responsable con el interesado. Sin embargo, la empresa ha de conservar todos los registros durante cuatro años y permanecerán a disposición de las personas trabajadoras, de sus representantes legales y de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

UNDÉCIMO: Las sanciones están reguladas en el artículo 83 del RGPD y 70 y siguientes de la LOPDGDD. En la normativa española, aparece un listado de infracciones que son en forma de ejemplo. En cambio el Reglamento regula diferentes sanciones administrativas.

Bibliografía

- *Agencia Española de Protección de Datos*. (18 de mayo de 2021). Recuperado el 18 de julio de 2022, de la-proteccion-de-datos-en-las-relaciones-laborales: <https://www.aepd.es/es/documento/la-proteccion-de-datos-en-las-relaciones-laborales.pdf>
- *Agencia Española de Protección de Datos*. (5 de abril de 2017). Recuperado el 20 de julio de 2022, de Directrices sobre los delegados de protección de datos (DPD): <https://www.aepd.es/sites/default/files/2019-09/wp243rev01-es.pdf>
- «Comisión Europea.» s.f. *Grupo de Trabajo respecto de la protección de Datos del artículo 29*. 30 de agosto de 2022. <https://ec.europa.eu/newsroom/article29/items>
- «Comisión Europea.» 11 de abril de 2018. *Guidelines on Transparency under Regulation 2016/679 (wp260rev.01)*. 20 de julio de 2022.. <https://ec.europa.eu/newsroom/article29/items/622227>
- «Comisión Europea.» 8 de junio de 2017. *Grupo de Trabajo del Artículo 29*. 20 de julio de 2022. <https://ec.europa.eu/newsroom/article29/items/610169>
- «Comisión Europea.» 6 de febrero de 2018. *Guidelines on Automated individual decision-making and Profiling for the purposes of Regulation 2016/679 (wp251rev.01)*. 24 de julio de 2022. <https://ec.europa.eu/newsroom/article29/items/612053>
- «Comité Europeo de Protección de Datos.» s.f. *Grupo de Trabajo del artículo 29*. 31 de agosto de 2022. https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/who-we-are_es
- Cruz Villalón, Jesús. Cruz Villalón, Jesús. *Protección de datos personales del trabajador en el proceso de contratación: facultades y límites de la actuación del empleador*. Albacete: Bomarzo, 2019.
- De Val Tena, Ángel Luis. «Asociación Española de Derecho del Trabajo.» 17 de abril de 2020. *La Protección de Datos Personales en los procesos de selección de los trabajadores; en particular, aquellos datos especialmente sensibles*. 11 de agosto de 2022. [https://www.aedtss.com/wp-content/uploads/dl/N119/06%20La%20proteccion%20de%20datos%20personales%20en%20los%20procesos%20de%20seleccion%20de%20trabajadores%20en%20particular,%20aquellos%20datos%20especialmente%20sensibles%20\(De%20Val%20Tena\).%20](https://www.aedtss.com/wp-content/uploads/dl/N119/06%20La%20proteccion%20de%20datos%20personales%20en%20los%20procesos%20de%20seleccion%20de%20trabajadores%20en%20particular,%20aquellos%20datos%20especialmente%20sensibles%20(De%20Val%20Tena).%20)
- *Dictamen 4/2007, de 20 de junio, sobre el concepto de datos personales, adoptado por el GT29*. 20 de junio de 2007. 27 de agosto de 2022. https://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2007/wp136_es.pdf
- «European Data Protection Board.» 4 de mayo de 2020. *Directrices 5/2020 sobre el consentimiento en el sentido del Reglamento (UE) 2016/679*. 31 de agosto de 2022. https://edpb.europa.eu/sites/default/files/files/file1/edpb_guidelines_202005_consent_es.pdf

- García-Núñez Serrano, Francisca. *La regulación sobre protección de datos personales su incidencia en el ámbito laboral*. 2000. Aranzadi.
- «Iberlex.» 6 de febrero de 2020. *Recogida de datos personales recopilados en procesos de selección de personal*. 20 de julio de 2022. <https://www.iberley.es/temas/recogida-datos-personales-recopilados-procesos-seleccion-personal-64331>
- Loza Corcera, María. *Tratamiento de datos personales en el ámbito laboral: análisis del Dictamen 2/2017 GT artículo 29*. 12 de septiembre de 2017. Legal Today.
- Mercader Uguina, Jesús Rafael. *Protección De Datos Y Garantía De Los Derechos Digitales En Las Relaciones Laborales*. 3a ed., Francis-Lefebvre, 2019 (libro electrónico).
- Martínez Rojas, Ángela. *Principales aspectos del consentimiento en el Reglamento de protección de Datos de la Unión Europea*. 2016. Aranzadi.
- Royo Pérez, Victoria. *Diez claves sobre protección de datos en el trabajo*. 20 de mayo de 2021. Noticias Jurídicas.
- Rubio Torrano, Enrique. *Del Reglamento europeo a la nueva Ley Orgánica de Protección de Datos*. 2018. Aranzadi.
- Tascón López, Rodrigo. *El tratamiento por la empresa de los personales de los trabajadores ¿un problema resuelto o caído en el olvido?* León, 2005. Aranzadi.

Jurisprudencia

- Sentencia nº 142/1993 del Tribunal Constitucional de 22 de abril de 1993.
- Sentencia nº 66/1995, del Tribunal Constitucional de 16 de mayo de 1995.
- Sentencia nº 55/1996, del Tribunal Constitucional de 28 de mayo de 1996.
- Sentencia nº 207/1996, del Tribunal Constitucional de 16 de diciembre de 1996.
- Sentencias nº 66/1995 del Tribunal Constitucional de 8 de mayo de 1995.
- Sentencias nº 55/1996 del Tribunal Constitucional de 28 de marzo de 1996.
- Sentencia nº 207/1996 Tribunal Constitucional de 16 de diciembre de 1996.
- Sentencia nº 37/1998, del Tribunal Constitucional de 17 de febrero de 1998.
- Sentencia nº 7922/2000 del Tribunal Supremo Sala de lo Contencioso de 31 de octubre de 2000.
- Sentencia nº 132/2000 del Tribunal Constitucional, de 16 de mayo de 2000.
- Sentencia 76/2001 del Tribunal Constitucional, de 26 de marzo de 2001.
- Sentencia 281/2005, del Tribunal Constitucional de 7 de noviembre de 2005.
- Sentencia nº 5361/2006 del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de fecha de 12 de julio de 2006.
- Sentencia. Nº nº 1799/2014. Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz de Tenerife. Sala de lo Social. 7 de abril de 2014.
- Sentencia nº recurso 899/2014 del Tribunal Supremo Sala Civil del 12 de noviembre de 2015.
- Sentencia nº 39/2016 del Tribunal Constitucional 3 de marzo de 2016
- Sentencia nº 817/2017 del Tribunal Supremo 2 de febrero de 2017.
- Sentencia nº 91/2017 del Tribunal Supremo Sala Civil de 15 de febrero de 2017
- §
– Sentencia nº recurso 249/2016 del Tribunal Supremo del 25 de enero de 2018
- Informe Jurídico nº 0201/2010 de la Agencia Española de Protección de Datos.

Normativa

- Constitución Española.
- Consejo de Europa.» 1 de abril de 2015. *Recomendación CM/Rec (2015)5, de 1 de abril de 2015, del Comité de Ministros del Consejo de Europa relativa al tratamiento de datos personales en el entorno laboral*. 30 de julio de 2022. https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805c3f7a
- Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical.
- Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales
- Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
- Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos).
- Texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

CLAÚSULA DE CONSENTIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO Y CESIÓN DE CV

Responsable: [NOMBRE_EMPRESA] - Teléfono de contacto: [NUM_TLF].

[NIF] - Correo electrónico: [CORREO_ELECTRÓNICO].

Dirección postal: [CALLE], [NUMERO], [LUGAR], [CIUDAD], [CÓDIGO_POSTAL], [PROVINCIA].

Delegado de Protección de datos: [ESPECIFIQUE AQUÍ, LOS DATOS DE CONTACTO DEL DELEGADO, SI ES EL CASO] (1)

[DENOMINACIÓN_SOCIAL] provisto de CIF núm. [NUMERO], le informa:

- Siguiendo el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, en lo referente al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos, los datos personales facilitados y recogidos en este currículum vitae [O SOLICITUD DE EMPLEO], serán tratados e incluidos automatizadamente en los ficheros de datos personales bajo responsabilidad de [DENOMINACIÓN_SOCIAL], con la finalidad exclusiva de formar parte en los procesos de selección de personal [BOLSA DE TRABAJO, CONTRATACIÓN, ETC.] que se lleven a cabo
- En el supuesto de producirse alguna modificación de sus datos personales, le solicitamos, nos lo comuniquen por escrito con la única finalidad de mantener actualizada su solicitud de empleo o currículum vitae.
- El titular de los datos personales consiente expresa e inequívocamente a que sus datos personales se cedan a otras organizaciones interesadas en determinados perfiles de trabajo.
- [DENOMINACIÓN_SOCIAL], garantiza el buen uso de la información, y en especial, la plena confidencialidad de los datos de carácter personal contenidos en nuestros ficheros, así como el pleno cumplimiento de las obligaciones en materia de protección de datos de carácter personal.
- Si necesita más información sobre el tratamiento de datos de carácter personal puede solicitárnosla, escribiéndonos a la cuenta: [CORREO_ELECTRÓNICO]. Asimismo, le informamos de la posibilidad que tiene de ejercer los Derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Oposición y Cancelación), mediante escrito dirigido al domicilio que consta en el encabezamiento del presente documento.

⁸³ «Iberlex.» 6 de febrero de 2020. *Recogida de datos personales recopilados en procesos de selección de personal*. 20 de julio de 2022. <https://www.iberley.es/temas/recogida-datos-personales-recopilados-procesos-seleccion-personal-64331>

Yo, D./Dña. [NOMBRE PERSONA CANDIDATA] con N.I.F. [NÚMERO], declaro que los datos que proporciono son reales y tras haber leído este documento y haber sido informado/a de todo lo anterior, autorizo y doy mi consentimiento expreso e inequívoco a [DENOMINACIÓN_SOCIAL], para el tratamiento de mis datos personales facilitados y para que los mismo se cedan a otras organizaciones involucradas en el proceso de selección e interesadas en determinados perfiles de trabajo. (2)

En [PROVINCIA], a [FECHA].

FIRMA PERSONA CANDIDATA].

(1) Especifique aquí, los datos de contacto del delegado (sólo si es el caso) incluyendo, dirección, teléfono, e-mail, y todos los datos que sean necesarios para la correcta identificación.

(2) El modelo otorga un consentimiento para la cesión del curriculum/solicitud y los datos personales con la única finalidad de tomar en consideración al interesado en procesos de selección y contratación celebrados por terceros. En el caso de transferencias internacionales, otras cesiones, o elaboración de perfiles deberán incorporarse dichos extremos al consentimiento.